



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003473/2021-21

Data do julgamento: 07/11/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado:

Francisco Frauendorf

Ementa: Atuação irregular como agente autônomo de investimento e outras alegadas irregularidades, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976, ao art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, ao art. 2º da Instrução CVM nº 558/2015, ao art. 13, incisos IV, VII e VIII, da Instrução CVM nº 497/2011, e item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979. Multas e proibição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de Francisco Frauendorf e a aplicação das seguintes penalidades:

(i) proibição temporária, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários e exercer qualquer atividade que dependa de autorização ou registro perante a CVM, pelo exercício irregular de administrado carteiras de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 2º da ICVM nº 306/1999 (quanto aos fatos ocorridos até 03.01.2016) e art. 2º da ICVM nº 558/2015 (quanto aos fatos ocorridos a partir de 04.01.2016) c/c art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011;

(ii) multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ter praticado operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, consoante definida na alínea “c” do item II da ICVM nº 8/1979 e vedada pelo item I;

(iii) multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter recebido e utilizado a senha dos Investidores, em infração ao disposto no art. 13,

(iv) multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter confeccionado e enviado extratos aos Investidores, em infração ao disposto no art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011.

O Colegiado decidiu, ainda, pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Resolução, o acusado punido com a penalidade de proibição temporária poderá requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 24/11/2023, às 16:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 24/11/2023, às 18:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 24/11/2023, às 19:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 02/12/2023, às 11:22, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1918495** e o código CRC **AD8E2CC7**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1918495** and the "Código CRC" **AD8E2CC7**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003473/2021-21

Reg. Col. 2386/21

Acusado: Francisco Frauendorf
Assunto: Atuação irregular como agente autônomo de investimento e outras alegadas irregularidades, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976, ao art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, ao art. 2º da Instrução CVM nº 558/2015, ao art. 13, incisos IV, VII e VIII, da Instrução CVM nº 497/2011, e item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Francisco Frauendorf (“Acusado”), agente autônomo de investimento¹, para apurar responsabilidades por, no período de 31.07.2015 a 16.03.2016, alegadamente, ter: (i) exercido irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários (“Carteira”), em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976², ao art. 2º da Instrução CVM (“ICVM”) nº 306/1999³ (para fatos até 03.01.2016)⁴, ao art. 2º da ICVM nº 558/2015⁵ (para fatos a partir de 04.01.2016) e ao art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011⁶; (ii) utilizado senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de clientes para transmissão de ordens em sistema eletrônico, em infração ao art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011⁷; (iii) confeccionado e enviado, a investidores, extrato de operações, por duas vezes, em 11.03.2016

¹ Neste relatório, será mantida a nomenclatura “agente autônomo de investimento” utilizada na acusação, por ser a que se utilizava à época dos fatos. Após as alterações promovidas pela Lei nº 14.317/2022 na Lei nº 6.385/1976, esses participantes de mercado passaram a ser denominados “assessores de investimentos”.

² Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

³ Art. 2º A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

⁴ A ICVM nº 306/1999 foi revogada e substituída pela ICVM nº 558/2015, que entrou em vigor em 04.01.2016, e que, por sua vez, foi revogada e substituída pela Resolução CVM (“RCVM”) nº 21/2021.

⁵ Art. 2º. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.

⁶ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: (...) IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários.

A ICVM nº 497/2011 foi revogada e substituída pela RCVM nº 16/2021.

⁷ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento (...): (...) VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e 15.03.2016, em infração ao art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011⁸; e (iv) realizado negociações de forma excessiva, com o objetivo de gerar receitas de corretagem e comissões para si ou para outrem (infração denominada “*churning*”), em infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM nº 8/1979⁹.

2. O PAS teve origem em irregularidades identificadas nos trabalhos de análise dos elementos contidos no Processo Administrativo (“PA”) CVM nº SP 2016-331¹⁰, instaurado pela SMI a partir de reclamação (“Reclamação”) feita pelos investidores M.A.B.P. e S.M.O. (em conjunto, “Reclamantes” ou “Investidores”), à CVM, em 11.08.2016¹¹, bem como no PA CVM nº 19957.004377/2017-13. Esse último teve como objeto o recurso interposto pelos Investidores contra decisão da BSM Supervisão de Mercados (“BSM”), que julgou improcedente o pedido de ressarcimento feito no processo movido no âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos nº 499/2016 (“MRP nº 499/2016”) ¹², quanto ao qual o Colegiado da CVM, em 04.02.2020, deu provimento parcial¹³, em favor da indenização de prejuízos sofridos pelos Investidores, até o limite da cobertura prevista no regulamento do MRP, com a devida correção monetária¹⁴.

3. O Acusado figurou como agente autônomo de investimento (“AAI”) registrado perante a CVM, entre 28.02.2008 e 18.05.2016, e manteve vínculo contratual com a corretora referida neste PAS (“Corretora”) entre 15.12.2015 e 07.04.2016¹⁵.

II. APURAÇÃO DOS FATOS E ACUSAÇÃO

4. O Termo de Acusação (“TA”) ¹⁶ veicula proposição da SMI de responsabilização do Acusado, à luz do seu entendimento quanto à existência de elementos suficientes de autoria e materialidade, ao amparo dos elementos de informação reunidos nos autos dos referidos processos

⁸ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento (...): (...) VIII - confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto.

⁹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.

A ICVM nº 8/1979 foi revogada e substituída pela RCVM nº 62/2022.

¹⁰ Doc. 1281979.

¹¹ Doc. 1281979, neste PAS, correspondente ao Doc. 0579366, fls. 1 a 28, do PA CVM nº SP-2016-331.

¹² Docs. 1282001, 1282006 e 1282009.

¹³ A íntegra da decisão do Colegiado consta da ata da reunião de 04.02.2020, disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200204_R1.html. Na ocasião, o caso retornou com o resultado de diligências solicitadas à SMI pelo Colegiado, em reunião de 11.09.2018, que restituiu o PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

¹⁴ Os Investidores solicitaram ressarcimento de R\$ 120.000,00 para cada uma das quatro operações contestadas em seu recurso à CVM, todavia, prevaleceu o entendimento da SMI que as operações realizadas, ainda que ocorridas em datas diferentes, eram parte da mesma conduta, posicionamento que foi acompanhado pelo Colegiado da CVM.

¹⁵ Doc. 0474584.

¹⁶ Doc. 1244675.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

administrativos. Assim, o relato das razões da Acusação está segregado conforme o apurado no PA CVM nº SP 2016-331 e no PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

II.a. PROCESSOS ORIGINÁRIOS

PA CVM nº SP 2016-331

5. O PA CVM nº SP 2016-331 foi instaurado para análise de reclamação de investidores/público em geral e teve como objeto a apuração da Reclamação, de 11.08.2016, em face da Corretora e de Francisco Frauendorf. Os Reclamantes descreveram diversas condutas que teriam resultado em prejuízos em operações cursadas no mercado de valores mobiliários, em alegadas infrações administrativas, destacando que potenciais ilícitos criminais já tinham sido objeto de requerimento de instauração de inquérito perante a autoridade policial competente.

6. Os elementos principais da Reclamação, descritos no TA, foram, em síntese:

- (a) em maio de 2015, Francisco Frauendorf apresentou aos Reclamantes um plano de investimento no mercado de capitais que consistiria na compra e venda de opções de compra e de opções de venda de ações, por intermédio da Corretora, o qual resultaria na obtenção de rendimento um pouco superior aos de instrumentos de renda fixa;
- (b) os Reclamantes abriram duas contas na Corretora, uma de titularidade de S.M.O. e outra de M.A.B.P., tendo transferido R\$ 740.792,00 e R\$ 1.306.483,00, respectivamente;
- (c) os Reclamantes também disponibilizaram a Francisco Frauendorf a senha de acesso a tais contas, uma vez que o Acusado teria explicado que utilizar a senha do *home broker* dos clientes era uma praxe comum quanto aos clientes com maior capital investido;
- (d) o Acusado teria prometido executar operações de renda fixa com estratégia de opções (de compra e venda) de ações, sendo o limite de perda de 3% e o de ganho de 10% por operação, enviando mensagens para os Investidores com explicações, sendo que a conta de M.A.B.P. seria utilizada para manter investimentos em renda fixa;
- (e) em outubro de 2015, estranhando a ausência de comunicações por parte do Acusado e considerando seu desconhecimento de operações de mercado, os Reclamantes consultaram o extrato das referidas contas e descobriram que Francisco Frauendorf havia perdido aproximadamente R\$ 200.000,00;
- (f) após insistência dos Reclamantes, o Acusado teria esclarecido que “*com a queda da bolsa da China, o mercado brasileiro estava ameaçando cair abaixo de 40.000 pontos, por isso entendeu por bem e sem prévio aviso e comunicação finalizar as operações para evitar maiores prejuízos*”; tendo apresentado um pedido de desculpas e solicitado uma nova “chance” para recuperar o referido prejuízo;
- (g) os Reclamantes, em 04.12.2015, decidiram retirar R\$ 2.020.000,00, que foram aplicados na conta de M.A.B.P. na Corretora, mas, atendendo a um “último pedido” de Francisco



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Frauendorf, deixaram R\$ 50.782,00 na conta de S.M.O. para que ele pudesse recuperar o valor perdido, por meio de negociações de pequeno valor, inclusive mediante promessa do então AAI de disponibilizar seu apartamento para “saldar o prejuízo causado”;

- (h) posteriormente, os Reclamantes efetuaram cadastro em site com informações sobre investimentos, que teria sido sugerido pelo Acusado, que se comprometeu a realizar operações recomendadas pelo portal, tendo então solicitado autorização dos Investidores para voltar a realizar operações de compra e venda de títulos no mercado à vista, o que foi autorizado pelos Investidores até o limite de R\$10.000,00/dia, montante posteriormente elevado, a pedido do AAI, para R\$ 100.000,00/dia, na condição de que as operações fossem realizadas de acordo com as recomendações do citado portal;
- (i) Francisco Frauendorf teria reiniciado as operações em 07.03.2016 e obtido ganhos nos pregões desse dia e dos dias subsequentes (8, 9, 10, 11 e 14), porém, em 15.03.2016, teria alegado que havia perdido montante na ordem de R\$ 70.000,00, mas que tal perda não teria impacto sobre os ganhos anteriores;
- (j) em 16.03.2016, S.M.O. recebeu sete e-mails do Departamento de Risco da Corretora, dentre os quais um em que essa comunicou que procederia liquidação compulsória. Segundo os Reclamantes, até tal data, nunca haviam recebido qualquer comunicação da Corretora, que em nenhum momento interveio, e que arcaram com o ônus de cerca de R\$ 429.000,00 em taxas operacionais e de corretagem; e
- (k) as operações realizadas pelo Acusado teriam sido totalmente distintas das que ele havia informado aos Reclamantes e os valores operados por Francisco Frauendorf, entre 07.03.2016 e 15.03.2016, chegaram a movimentar R\$ 15.582.148,00, em 11.03.2016, e R\$ 20.538.673,00, em 15.03.2016.

7. Na visão dos Investidores, a postura da Corretora teria oscilado entre (i) reconhecer a falha no dever de supervisionar o então AAI por ela contratado; e (ii) sustentar que não tinha responsabilidade pelos prejuízos, que teriam decorrido da entrega ao AAI da senha de acesso de cliente aos sistemas da Corretora. Segundo a Acusação, quando instada a se manifestar no processo, a Corretora manteve esse argumento, alegando que “*verificou que as operações supostamente não autorizadas foram executadas pela própria cliente*” por meio do *home broker*, e que “*a própria cliente confessou que compartilhou esses dados com terceiros*”¹⁷.

8. Após as diligências pertinentes, a SMI tomou conhecimento de que a BSM havia instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 24/2017 (“PAD BSM nº 24/2017”)¹⁸, em face de Francisco Frauendorf, diante de irregularidades identificadas na análise do pedido formulado pelos

¹⁷ Doc. 0579366, fls. 39 a 41, do PAS CVM nº SP 2016-331 (Doc. 1281979 neste PAS).

¹⁸ Doc. 1030592 do PAS CVM nº SP 2016-331.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores no MRP nº 499/2016, de modo que optou-se por aguardar seu desfecho¹⁹.

9. Em 28.02.2018, a BSM acusou Francisco Frauendorf de ter transmitido ordens em nome dos Reclamantes por meio de plataforma de negociação de *home broker* do intermediário, “*de uso exclusivo de cliente final, utilizando senha e assinatura eletrônica dos Reclamantes no período de 31.7.2015 a 16.6.2016*”, conforme o termo de acusação do PAD BSM nº 24/2017²⁰.

10. Em 01.11.2018²¹, a SMI informou à BSM que identificara indícios de giro excessivo na carteira dos investidores (*churning*) e que, por ter verificado que esse ponto não tinha sido abordado no MRP nº 499/2016, nem no PAD BSM nº 24/2017, solicitava, com base no art. 83 da ICVM nº 461/2007, que fossem analisados os negócios realizados para indicar se havia indícios de *churning*, considerando os indicadores de *turnover ratio* e *cost-to-equity ratio*, além das demais considerações de praxe capazes de amparar uma análise conclusiva a respeito²².

11. Em resposta²³, a BSM informou que as negociações em nome de M.A.B.P. não demonstravam volume alavancado de operações nem pagamento de custos excessivos, sem o que não se configuraria *churning*. Já em relação às operações de S.M.O., segundo a BSM:

“Os indicadores de *churning* para as operações em nome de [S.M.O.] demonstram volume alavancado de operações e pagamento de custos excessivos à [Corretora] e ao agente autônomo de investimento Francisco Frauendorf. No entanto, uma vez que a investidora compartilhou suas credenciais de acesso com o agente autônomo de investimento, delegando a ele o poder de comando para realizar operações em seu nome, e como ambos mantiveram diálogos frequentes a respeito das decisões sobre manutenção de tais operações, não há ausência de autorização ou de ciência da investidora (conta capturada), o que descaracteriza a prática de *churning*”.

12. Como consta do TA²⁴, a SMI entendeu que a atuação da BSM, no caso, teria sido insuficiente e, após ter verificado, em pesquisa realizada em 22.04.2021, que o PAD BSM nº 24/2017 constava como “*em andamento*”, com proposta de termo de compromisso em seu âmbito, optou por instaurar o presente PAS, nos termos do artigo 49 da ICVM nº 461/2007²⁵.

¹⁹ O PAD BSM nº 24/2017 só analisou o descumprimento da vedação contida no art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011.

²⁰ Doc. 1030592 do PAS CVM nº SP 2016-331.

²¹ O questionamento cumpriu determinação do Colegiado da CVM, em análise do PA CVM nº 19957.004377/2017-13, cujo objeto consistia em recurso dos Reclamantes contra decisão da BSM desfavorável ao pleito de ressarcimento desses investidores pelo MRP. Na ocasião, o referido órgão deliberou pela restituição dos autos à SMI para realização de diligências adicionais (v. ata disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180911_R1.html).

²² Doc. 1030593 do PAS CVM nº SP 2016-331.

²³ Doc. 1030596 do PAS CVM nº SP 2016-331.

²⁴ Doc. 1244675.

²⁵ Art. 49. A violação das normas cuja fiscalização incumba ao Departamento de Auto-Regulação sujeita seus infratores às penalidades previstas em regulamento.

A ICVM nº 461/2007, que foi revogada pela RCVI nº 135/2022, não excluía a possibilidade de a CVM instaurar processo administrativo sobre fatos já apurados no âmbito da autorregulação, apenas estabelecendo algumas regras a serem observadas pela Autarquia para aplicação de penalidades nos casos em que penas já tiverem sido impostas pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PA CVM nº 19957.004377/2017-13

13. Os fatos apurados no PA CVM nº SP 2016-331 também foram trazidos ao conhecimento da CVM pelo Ofício/BSM/SJUR/MRP-0915, de 15.05.2017, que encaminhou recurso interposto pelos Investidores, em 11.05.2017, em face de decisão do Diretor de Autorregulação da BSM que julgou improcedente reclamação por eles apresentada nos termos do MRP nº 499/2016. Assim, em 17.05.2017, a SMI instaurou o PA CVM nº 19957.004377/2017-13²⁶ para análise da decisão que negou tal ressarcimento pleiteado pelos Reclamantes (art. 82, p.ú., da ICVM nº 461/2007)²⁷.

14. Como consta da reclamação ao MRP²⁸, os Investidores entendiam que faziam “*jus, pelo menos, ao ressarcimento dos prejuízos havidos nos dias 11/03, 15/03, 16/03 e 13/04, até o limite, por operação, de R\$ 120.000,00*”, perfazendo o total de R\$ 480.000,00. Segundo alegaram, tal valor, “*nem de longe*”, seria capaz de “*suprir todo o prejuízo financeiro dos Reclamantes mencionado acima de R\$ 2.420.472,43*”, computando-se o valor de “*taxas cobradas no mercado de capitais*”, sendo, apenas, uma diminuição do prejuízo para “*subsistência dos reclamantes*”.

15. Ainda no âmbito do MRP, em 11.11.2016, os Reclamantes informam à BSM que ajuizaram ação judicial com pedido cautelar de arresto²⁹, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, São Paulo, em face da Corretora e de Francisco Frauendorf, tendo sido deferida, liminarmente, a ordem de bloqueio das contas bancárias do AAI, no valor de R\$ 1.985.472,43.

16. A BSM, na instrução do MRP nº 499/2016, ouviu a Corretora³⁰ que, em sua defesa, assinalou, inicialmente, que os Reclamantes tinham estabelecido relação contratual exclusiva com Francisco Frauendorf, sem o conhecimento da Corretora, relação essa que se formou quando constituíram o AAI como mandatário com amplos poderes de gestão sobre seus recursos, para que fossem investidos no mercado. Para viabilizar esse serviço de gestão, teriam então compartilhado com Francisco Frauendorf suas senhas de acesso ao sistema *home broker* (pessoais e intransferíveis), o que ocorreu igualmente sem o conhecimento da Corretora.

17. Foi aduzido que os Reclamantes e o AAI tinham laços de confiança e amizade que perduraram por cerca de 7 meses, até que, segundo os Investidores, esse teria realizado operações malsucedidas que levaram, então, aos prejuízos. Teria sido a partir dessa “*má execução*” do mandato, que os Investidores teriam ingressado com o pedido de ressarcimento ao MRP e, em

autorregulação, nos termos dos §§ 5º e 6º do referido art. 49.

²⁶ Os autos do PA CVM nº 19957.004377/2017-13 constam dos Docs. 1282001, 1282006 e 1282009 deste PAS.

²⁷ Art. 82. A decisão sobre o pedido de ressarcimento deve ser imediatamente comunicada às partes, contendo, no mínimo: (...) Parágrafo único. O reclamante pode apresentar recurso à CVM da decisão que tiver negado o ressarcimento.

²⁸ Doc. 0280319 do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

²⁹ Processo nº 1026277-95.2016.8.26.0577, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”).

³⁰ Doc. 0280319, p. 42.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

paralelo, movido processo judicial em face dos reclamados.

18. A Corretora reconheceu ter o dever de fiscalizar as atividades dos AAIs que atuassem em seu nome, nos termos do art. 17, II, da ICVM nº 497/2011³¹, então vigente, e que falhas nesse dever de fiscalização que acarretassem prejuízo aos investidores acarretariam o dever de responder pelos atos praticados pelo AAI por ela contratado, conforme o disposto no art. 15 da ICVM nº 497/2011³². Todavia, no caso concreto, a instituição afirmou que não foram preenchidos os requisitos para que se caracterizasse sua responsabilidade, quais sejam: (i) falha de seu dever de fiscalização, de modo a permitir alguma irregularidade do AAI; e (ii) nexo de causalidade entre a irregularidade praticada pelo AAI e o prejuízo sofrido pelos investidores.

19. A Corretora defendeu, em síntese, que as alegadas irregularidades que teriam sido praticadas por Francisco Frauendorf, dispostas nos incisos IV e VII do art. 13 da ICVM nº 497/2011, não ocorreram por culpa da Corretora, mas sim da vontade dos Reclamantes, que quiseram que o AAI gerisse sua carteira e entregaram a ele suas senhas, pessoais e intransferíveis.

20. A propósito, a Corretora citou as cláusulas 15.1 e 15.2 do contrato de intermediação assinado pelos Reclamantes, que expressamente estabelecem que o cliente estaria ciente de que a senha de utilização dos sistemas eletrônicos seria de uso exclusivo, pessoal e intransferível³³, de modo que as operações feitas via *home broker* seriam consideradas como efetuadas diretamente pelos clientes. Ou seja, como as operações eram realizadas por este sistema, “aos olhos da [Corretora]” estavam sendo conduzidas pelos próprios Reclamantes.

21. A Corretora apontou, ainda, como prova inconteste, a seu ver, de que os Reclamantes estavam dispostos a correr riscos nessas operações, o fato de que, após terem tomado conhecimento de perdas de R\$ 200.000,00, mesmo assim terem seguido dando poderes ao AAI para continuar gerindo seus recursos. A instituição, a fim de corroborar o afirmado quanto a que os Investidores almejavam alta rentabilidade no curto prazo, incorrendo naturalmente em maiores riscos, reproduziu diálogo³⁴ mantido por meio de aplicativo (WhatsApp) entre M.A.B.P. e Francisco Frauendorf, em 27.07.2015, por meio do qual o reclamante pede a opinião do AAI sobre um fundo de investimento que teria apresentado rentabilidade expressiva no ano, sinalizando interesse de operações de alta rentabilidade no curto prazo. Citando decisão do TJ-SP, a Corretora asseverou que quem busca lucro relevante de curto prazo no mercado mobiliário “*sabe que está*

³¹ Art. 17. A instituição integrante do sistema de distribuição deve: (...) II - fiscalizar as atividades dos agentes autônomos de investimento que atuem em seu nome de modo a garantir o cumprimento do disposto nesta Instrução e nas regras e procedimentos estabelecidos nos termos do inciso I.

³² Art. 15. A instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários responde, perante os clientes e perante quaisquer terceiros, pelos atos praticados por agente autônomo de investimento por ela contratado.

³³ Doc. 0280319, p. 39, do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

³⁴ Doc. 0280319, p. 39, do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

exposto a riscos e não pode alegar surpresa em caso de revés”³⁵.

22. A BSM, por sua vez, em 10.04.2017³⁶, julgou improcedente o pedido dos Reclamantes, por entender não configurada hipótese de ressarcimento pelo MRP (art. 77 da ICVM nº 461/2007)³⁷.

23. A decisão em tela considerou, primeiramente, o parecer da Superintendência Jurídica da BSM (“SJUR”)³⁸ que, ao analisar o mérito da reclamação, concluiu que os prejuízos decorreram exclusivamente de operações realizadas em nome dos Investidores por intermédio do *home broker* e que as evidências trazidas aos autos demonstraram que houve negligência ao transferirem senhas e assinaturas eletrônicas a agente autônomo, não obstante terem ciência de que tais senhas eram de uso exclusivo, pessoal e intransferível, sendo expressamente vedada a entrega a AAIs e a correspondentes bancários e demais prepostos, nos termos da cláusula 17 do contrato de intermediação firmado com a Corretora. Ademais, as comunicações frequentes via WhatsApp entre as partes, anexadas à reclamação³⁹, comprovariam que os Reclamantes tinham plena ciência e consentiam com a administração de suas contas pessoais por terceiro, demonstrando, assim, que tinham conhecimento do mercado e acompanhavam as operações.

24. O Diretor de Autorregulação⁴⁰ da BSM, apoiado no referido relatório da SJUR, entendeu que não se estava diante de um caso que caracterizava hipótese de ressarcimento pelo MRP, e indeferiu o pedido, mas determinou a apuração da irregularidade consistente no uso, pelo AAI, de senha eletrônica de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por sistema eletrônico, nos termos do inciso VII do art. 13 da ICVM nº 497/2011.

25. No recurso interposto em 11.05.2017, os Reclamantes, além de contestarem a decisão da BSM, questionaram os elevados valores cobrados por conta de taxas de corretagem e de operação cobrados – aproximadamente R\$ 429.000,00 – e aduziram que houve falta de supervisão por parte da Corretora acerca das atividades de seu preposto.

26. Inicialmente, a SMI manifestara⁴¹ opinião pelo indeferimento do recurso, considerando que o fato de os Recorrentes terem fornecido suas senhas ao agente autônomo geraria a presunção de autorização tácita para que esse operasse como seu mandatário. Todavia, a partir de diligências

³⁵ Doc. 0280319, p. 40, do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

³⁶ Doc. 0280319, p. 105, do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

³⁷ Art. 77. A entidade administradora de mercado de bolsa deve manter um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, com a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos decorrentes da ação ou omissão de pessoa autorizada a operar, ou de seus administradores, empregados ou prepostos, em relação à intermediação de negociações realizadas na bolsa ou aos serviços de custódia, especialmente nas seguintes hipóteses (...).

³⁸ Doc. 0280319, p. 72-100, do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

³⁹ A SJUR reproduziu os diálogos com o assessor, sobre essas negociações, nas datas de 14.08, 04.09, 24.09, 25.09 e 29.10.2015, bem como em 10 e 11.03.2016.

⁴⁰ Doc. 0280319, p. 101-105, do PA CVM nº 19957.004377/2017-13.

⁴¹ Memorando nº 114/2018-CVM/SMI/GME (Doc. 0583912 do PA CVM nº 19957.004377/2017-13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

adicionais determinadas pelo Colegiado, a SMI emitiu nova opinião, pelo provimento parcial do recurso⁴², por entender que o prejuízo sofrido decorrera, na verdade, de ações tomadas pelo AAI, que operava em nome dos Investidores, fazendo uso da senha desses e efetuando operações que geraram custo elevadíssimo, com indícios da ocorrência de *churning*.

27. No caso, entendeu-se que tal atuação do preposto, na verdade, permitia pressupor que esse induzia os Investidores a erro, ficando assim caracterizado o nexo causal entre suas ações e o prejuízo por eles sofrido, caracterizada a infiel execução de ordem, hipótese de ressarcimento prevista no inciso I do art. 77 da ICVM 461/2007⁴³. O Colegiado, em linha com a SMI, deliberou pelo provimento parcial do recurso, concedendo-se o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos Reclamantes até o limite da cobertura prevista no regulamento, de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), porquanto todas as operações realizadas evidenciavam o mesmo nexo de causalidade – a infiel execução de ordens pela reclamada, conforme precedente estabelecido pelo Colegiado⁴⁴.

II.b. ALEGADAS INFRAÇÕES

28. Como descrito no Termo de Acusação, a Área Técnica entendeu que o Acusado:

- a) nunca teve registro/autorização para atuar como administrador de Carteira (infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 2º da ICVM nº 558/2015 c/c art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011);
- b) recebeu e utilizou senha de investidor (infração ao art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011);
- c) confeccionou e enviou para cliente extrato contendo informações sobre as operações realizadas (infração ao art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011); e
- d) realizou negociações excessivamente com o objetivo de gerar receitas de corretagem e comissões para si ou para outrem (“*churning*”) (infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979).

29. São relatados, a seguir, de forma detalhada, os elementos levaram às acusações acima e à comunicação ao Ministério Público competente de indícios de crime de ação penal pública.

II.b.1. Administração irregular de carteira de valores mobiliários

30. No que tange à primeira imputação, a SMI apresentou material probatório, incluindo declarações do Acusado em inquérito policial e no PAD BSM nº 24/2017, a corroborar a tese de

⁴² Memorando nº 13/2020-CVM/SMI/GME (Doc. 0922443 do PA CVM nº 19957.004377/2017-13).

⁴³ Art. 77 A entidade administradora de mercado de bolsa deve manter um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, com a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos decorrentes da ação ou omissão de pessoa autorizada a operar, ou de seus administradores, empregados ou prepostos, em relação à intermediação de negociações realizadas na bolsa ou aos serviços de custódia, especialmente nas seguintes hipóteses: I - inexecução ou infiel execução de ordens; (...).

⁴⁴ PA CVM nº 19957.004043/2016-69.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

que Francisco Frauendorf desempenhou a atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem o devido registro perante a CVM (pois nunca o teve) e em infração à regra que proibia AAI de contratar com clientes tais serviços, mesmo que a título gratuito.

31. O TA repisou que a atividade de administração de carteira de valores mobiliários é caracterizada quando presentes quatro elementos: (i) a gestão, assim entendida como a liberdade para executar a estratégia de investimento estabelecida e os passos necessários para sua concretização, comunicando-os ao cliente posteriormente; (ii) a realização em caráter profissional, como aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado; (iii) a entrega de recursos ao administrador para que este os administre; e (iv) a autorização, expressa ou tácita, para compra ou venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor⁴⁵.

32. Pontuou que Francisco Frauendorf jamais solicitou ou recebeu autorização da CVM para atuar como administrador de carteira de valores mobiliários, sendo possível concluir que o Acusado assim o fez a partir de suas próprias declarações no Inquérito Policial 459/2016⁴⁶ (“Inquérito Policial”), dos quais a área técnica destacou os seguintes trechos:

(i) “[realizou] operações de investimento na forma da legislação e regulamentação em vigor, expressamente autorizadas por eles, inclusive, com a liberação de senha, no âmbito de sua discricionariedade, com plena assunção, por eles, dos riscos, especialmente os de suportar perda financeira em decorrência de liquidação das operações, em face da imprevisibilidade e da volatilidade, próprias do conjunto das operações, à partir de contas mantidas por eles junto à [Corretora]”; (ii) “que sua remuneração na forma da legislação e regulamentação em vigor, era um percentual da taxa gerada pela aplicação dos clientes cadastrados junto à [Corretora]”; (iii) “que operava as senhas de [M.A.B.P. e S.M.O.] livre e espontaneamente fornecida por eles e [M.A.B.P.] acompanhava, diariamente, mediante *log in* todas as operações”; (iv) “que as operações eram sempre autorizadas pelo casal”; (v) “que desde agosto de 2015 fazia as operações para [M.A.B.P. e S.M.O.], sempre autorizado por eles que checavam, diariamente, as operações, e [M.A.B.P.] recebia todas as notas de corretagem e acessava as contas frequentemente”; (vi) “que o declarante decidia o que comprar, porém sempre com o acompanhamento do [M.A.B.P.] e os indicadores de mercado e do site (...)”.

33. Segundo a Acusação, as declarações de Francisco Frauendorf no âmbito do PAD BSM nº

⁴⁵ Nesse sentido, são citados os seguintes precedentes do Colegiado: PAS CVM nº SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº RJ 2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS CVM nº RJ 2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.3.2009; PAS CVM nº RJ 2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10.07.2012; PAS CVM nº RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria, j. em 08.09.2015; PAS CVM nº SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 06.10.2015.

⁴⁶ Vide fls. 66, do PA CVM nº SP-2016-331, Termo de Declarações I.P. 549/1/2016, Primeiro Distrito Policial de S.J. dos Campos-SP. No PA CVM nº SP-2016-331, o referido termo de declarações corresponde ao Doc. 0579366, o qual foi incorporado neste PAS, no arquivo eletrônico disponível no Doc. 1281979.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

24/201747 também configuram confissão em relação à referida imputação, tendo o Acusado alegado que os Recorrentes o autorizaram *“livre e espontaneamente, expressamente, no exercício de sua própria discricionariedade, a realizar todas as operações, através do home broker”*.

34. Ademais, para a Acusação, o conjunto de mensagens, escritas e por voz, trocadas entre Francisco Frauendorf e M.A.B.P., corroboradas pelas operações financeiras registradas em nome dos Reclamantes, além dos elementos supracitados, permitiriam verificar a presença do elemento “gestão”, porquanto o AAI teria ampla liberdade, concedida pelos Reclamantes, para escolher o momento de iniciar e encerrar posições de investimentos, os ativos e as quantidades a serem negociadas, bem como a direção (compra ou venda) a ser assumida, sendo que, em diversos momentos, o agente autônomo prestava contas das operações realizadas.

35. Neste sentido, apontou as trocas de mensagens entre Francisco Frauendorf e M.A.B.P.⁴⁸, citadas no TA, referentes aos dias: 14.08.2015 (*“ações de emissão do Itaú Unibanco S.A.”*); 13.10.2015 (*“day trade com opções de compra de ações de emissão do Bradesco”*); 14.12.2015 e 15.12.2015 (compra e venda de *“opções de compra de ações de emissão do Bradesco S.A.”*); e 08.03.2016⁴⁹ (operações com diversos valores mobiliários). Segundo a SMI, todos esses diálogos citavam operações que de fato ocorreram, como corroboram as notas de corretagem dessas datas.

36. Adicionalmente, ainda segundo a Acusação, os demais elementos para caracterização da administração de carteira teriam restado comprovados no caso concreto, nos seguintes termos:

- a) o caráter profissional da gestão, pois o AAI, atuando em nome da Corretora, a partir de vínculo contratual, era remunerado com base na receita auferida pela Corretora com a taxa de corretagem incidente sobre os negócios intermediados para os clientes atendidos⁵⁰; e
- b) os elementos de “entrega de recursos ao administrador para que este os administre” e de “autorização, expressa ou tácita, para compra ou venda de títulos e valores mobiliários” teriam sido demonstrados pelo fato de os Investidores terem fornecido dados de *login* e senha de acesso ao sistema de *home broker* disponibilizado pela Corretora, bem como pelo acompanhamento constante por parte de M.A.B.P. dos referidos investimentos realizados.

II.b.2. Uso de senhas de uso exclusivo do cliente para transmitir ordens em sistema eletrônico

37. Para a Acusação, Francisco Frauendorf também violou o disposto no art. 13, VII, da ICVM

⁴⁷ Cópia do PAD BSM nº 24/2017 foi juntada aos autos do SP-2016-331, no doc. 1030592. O trecho acima referido, registrado às fls. 192-194, consta da resposta encaminhada à BSM, em que ele informa que atuava como AAI cumprindo as orientações dos investidores, juntando mensagens que comprovariam autorização e incentivo desses.

⁴⁸ Doc. 0757114, pasta “anexo III”, arquivo “whatsapp s3”.

⁴⁹ Doc. 0757109, fls. 15, 171, 288 e 289.

⁵⁰ No Doc. 0757109, constante do PA CVM nº 19957.004377/2017-13, consta o arquivo “Defesa_CD.zip”, que apresenta, entre outros documentos, a pasta “Documentos AAI” com o “Contrato de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários” entre a Corretora e o AAI.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nº 497/2011, ao utilizar senhas do *home broker* de uso exclusivo dos Reclamantes, prática vedada aos AAI. Além das declarações do Acusado (no Inquérito Policial e no PAD BSM nº 24/2017) e do conjunto de mensagens trocadas entre ele e M.A.B.P. (corroboradas pelas operações feitas), a área técnica considerou, ainda, a resposta do Acusado⁵¹ ao Ofício nº 59/2021/CVM/SMI/GME⁵².

38. Na referida resposta do AAI ao ofício da GME, de 05.03.2021, embora ele afirme nunca ter havido administração irregular das carteiras de valores dos investidores, pois, segundo alegou, *“ambos acompanhavam, controlavam e orientavam, diariamente, as aplicações realizadas”*, o Acusado terminou por corroborar que as operações *“somente agora impugnadas pelos investidores sempre foram realizadas por meio de sua senha de acesso ao sistema home broker, por eles e pelo Agente Autônomo, simultaneamente, em livre regular exercício da discricionariedade e liberalidade deles investidores”*.

39. A SMI considerou, ainda, as declarações de Francisco Frauendorf no âmbito do PAD BSM nº 24/2017, que apurou a mesma infração⁵³.

II.b.3. Confeção e envio para clientes de extrato contendo informações sobre as operações realizadas em seus nomes

40. A SMI apontou, a partir de mensagens de Francisco Frauendorf enviadas pelos Reclamantes⁵⁴, que o Acusado confeccionou e enviou, em duas oportunidades, em 11.03.2016 e 15.03.2016, extratos contendo informações sobre as operações realizadas em nome dos Reclamantes, prática vedada aos AAI pelo art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011.

41. O Acusado, no entendimento da SMI, corroborou tal prática por meio das declarações dadas no âmbito do Inquérito Policial, ao alegar *“a pedido de [M.A.B.P.], que monitorava e acompanhava, diariamente, as operações com mais detalhes, pedia ao declarante que mandasse os resultados, o que optou por fazer através de planilhas”*⁵⁵. Tais planilhas, encaminhadas pelo Acusado a M.A.B.P., continham os valores referentes ao “lucro líquido” obtido nas operações.

II.b.4. Churning

42. A Acusação entendeu que o Acusado negociou excessivamente ativos que compunham a

⁵¹ Doc. 1234595 do PAS CVM nº SP 2016-331.

⁵² Doc. 1211574 do PAS CVM nº SP 2016-331.

⁵³ Em decisão transitada em julgado, no PAD BSM nº 24/2017, o Francisco Frauendorf foi condenado, por infração ao art. 13º, VII, da ICVM nº 497/2011, ao pagamento de multa de R\$200.000,00, em caráter definitivo. A decisão da Instância Recursal do Conselho de Supervisão da BSM está disponível em: <https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-processos/parecer/2017-24-pad>. Cópia do PAD BSM foi juntada aos autos do PA CVM nº SP-2016-331 (Doc. 1030592), constando também deste PAS (Doc. 1281979).

⁵⁴ Imagens e áudio de Francisco Frauendorf discorrendo acerca das imagens no Doc. 0757114, pasta anexo IV.

⁵⁵ Doc. 0579366, fls. 89 e 90.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

carteira de investimentos dos Reclamantes, com o propósito de auferir vantagem financeira indevida, consistente em percentual que recebia das receitas de corretagem referentes a esses negócios, em detrimento dos interesses desses clientes.

43. Consoante destacou a área técnica, na peça acusatória, a configuração da prática de *churning*, de acordo com o entendimento consolidado pelos precedentes da CVM⁵⁶, requer que seja demonstrado: (a) o controle que o indivíduo detinha sobre as operações cursadas em nome do investidor; (b) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente; e (c) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões para si ou para *outrem*.

44. No que se refere ao primeiro requisito, a SMI entendeu que o controle do AAI sobre as carteiras de investimentos dos Reclamantes, no período analisado, restou amplamente comprovado. A descrição da forma de atuação do agente autônomo teria evidenciado que o profissional podia controlar as operações com os valores mobiliários de titularidade dos Investidores, inclusive pelo acesso aos dados de *login* e senhas pessoais dos clientes.

45. No que concerne ao segundo requisito, a BSM, por solicitação da SMI, analisou os negócios mantidos no período, utilizando os indicadores de praxe⁵⁷, e identificou volume alavancado de operações e pagamento de custos excessivos à Corretora e ao AAI no que se refere à carteira de S.M.O.: *turnover ratio* de 84 e *cost-to-equity ratio* de 42%⁵⁸.

46. Os cálculos da BSM foram revisados pela SMI. Como o autorregulador utilizou valores estimados para as despesas de negociação, a Acusação optou por computar os valores efetivos constantes das notas de corretagem juntadas aos autos. Concluiu, assim, que o custo total de negociação foi um pouco menor (R\$ 274.918,85, ao invés de R\$ 297.347,34), levando a um *cost-to-equity ratio* de 62,11%. Quanto ao giro, a SMI também ajustou o indicador para computar o período efetivo das operações (aprox. 7,5 meses), levando a um novo giro da carteira, de 134,42.

47. Diante desses dados, a Acusação concluiu que os indicadores excediam amplamente os parâmetros que são usualmente considerados para concluir pela prática de *churning*, acrescentando, ademais, que, quanto maiores são tais índices, maior valor probatório deve a eles

⁵⁶ Foram citados, p.ex., PAS CVM nº SP2012/480, j. em 06.10.2015, Rel. Dir. Roberto Tadeu; PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 10.02.2017, Rel. Dir. Pablo Renteria; PAS CVM nº 11/2013, j. em 30.01.2018, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez; PAS CVM nº RJ2015/6143, j. em 24.04.2018, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez; PAS CVM nº 22/2013, j. em 18.09.2018, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez; PAS CVM nº SP2014/0465, j. em 06.11.2018, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez.

⁵⁷ Como explanou o TA, dois indicadores financeiros são utilizados para caracterização de *churning*: a taxa de giro da carteira de investimentos (*turnover ratio* – TR) e a razão dos custos de negociação sobre o patrimônio da carteira de investimento (*cost-to-equity ratio* – C/E). O tema é abordado, no mercado brasileiro, pelo Relatório de Análise BSM 001/2011 (Doc. 1244813) e estudo da CVM (Doc. 1244816), usualmente utilizados como referência, em conjunto com os precedentes do Colegiado da Autarquia, já mencionados. Uma síntese das considerações pertinentes a respeito do cálculo de tais índices está apontada no TA (Doc. 1244675, fls. 9-10).

⁵⁸ Esses são os indicadores que constam do Ofício 0294/2019-DAR-BSM, nos autos do PA CVM nº SP-2016-331.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ser atribuído, em consonância com entendimento já manifestado pelo Colegiado⁵⁹.

48. No que tange ao requisito de gerar receitas de corretagem e comissões para si ou para outrem, a Acusação também concluiu que está presente no caso, uma vez que o AAI percebia percentuais da receita auferida pela Corretora, seja em nome próprio, seja por meio de pessoa jurídica AAI de sua titularidade (“AAI PJ”), conforme contratos firmados com a Corretora⁶⁰.

49. Assim, seguindo precedentes do Colegiado, a Acusação concluiu que a atuação do AAI caracterizou a realização de operação fraudulenta, vedada pelo item I c/c item II, “c”, da ICVM nº 8/1979, considerando as operações realizadas por Francisco Frauendorf, por terem restado presentes os três elementos configuradores da infração:

- (a) a utilização de ardil ou artifício – caracterizado pelo giro excessivo da carteira, sendo que o AAI enviava mensagens para M.A.B.P. com a descrição de operações realizadas, mas sem mencionar os custos que corroíam o valor da carteira de investimentos⁶¹;
- (b) para induzir ou manter terceiros em erro – os Reclamantes acreditaram que os recursos disponibilizados ao Acusado eram administrados dentro de uma estratégia legítima e de boa-fé em que se perseguia a lucratividade nas operações com valores mobiliários; e
- (c) com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial – as taxas excessivas de corretagem, que beneficiariam o AAI, conforme apontado em precedente da CVM⁶².

50. Por fim, a Acusação discordou da conclusão da BSM de que o fornecimento do *login* e senha pessoais ao Acusado descaracterizaria a prática de *churning*, entendendo, ao revés, ser “*mais um elemento a demonstrar o abuso da confiança depositada pelos Reclamantes no Acusado*”⁶³.

⁵⁹ PAS CVM nº 11/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2018.

⁶⁰ V. Anexo 1 (Percentuais de Comissionamento) ao Contrato de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários firmado entre a Corretora e Francisco Frauendorf em 21.10.2014, bem como o Contrato Global de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários para Agentes Autônomos de Investimento e o Contrato Específico de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários para Agentes Autônomos de Investimento, estes estabelecidos entre a Corretora e a AAI PJ do Acusado (Doc. 0757109 (Anexo_1_CD_Defesa) do PA CVM nº 19957.004377-2017-13).

⁶¹ Como ressaltado no TA (fls. 11): “*não se cogita a situação de um investidor que delegaria a gestão de seus recursos se soubesse que a rentabilidade anual teria que ser de 62,11% somente para compensar os custos de negociação. Por mais arrojado e propenso a risco que fosse determinado investidor, soa impensável que ele concordasse com tratamento tão desfavorável e desleal de seus recursos*”.

⁶² PAS CVM nº SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, item 36: “*a taxa excessiva de corretagem é a vantagem patrimonial obtida por meio da fraude*”.

⁶³ No PAS CVM nº SP2012/480, j. em 06.10.2015, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, a SMI sustentou que um dos acusados, “*dispondo de controle sobre os recursos do Reclamante, realizou uma quantidade excessiva de operações de compra e venda de valores mobiliários, motivado, certamente, pelo fato de que parcela de sua remuneração estava diretamente relacionada com o total pago a título de corretagem*”. Entendeu o Relator, no que foi acompanhado pelo Colegiado, que o investidor foi mantido em erro pelos acusados, uma vez que, “*por disporem do total controle dos recursos investidos foram capazes de gerar taxas excessivas de corretagem e, por consequência, obterem vantagem patrimonial consistente no recebimento de parcela das taxas, caracterizando a prática de operação fraudulenta, conceituada nos termos do supracitado item II, ‘b’, da Instrução CVM nº 8/79*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II.b.5 Manifestação Prévia do Acusado

51. Instado a se manifestar sobre as alegadas infrações por meio do Ofício nº 59/2021/CVM/SMI/GME⁶⁴, o Acusado sustentou⁶⁵, em síntese, que:

- (a) não houve administração irregular das carteiras dos Reclamantes, uma vez que “*ambos acompanhavam, controlavam e orientavam, diariamente, as aplicações efetuadas*”⁶⁶;
- (b) as operações dos Investidores foram sempre “*realizadas por meio de sua senha de acesso ao sistema de home broker, por eles e pelo Agente Autônomo, simultaneamente*”;
- (c) “*os extratos eram regularmente enviados diretamente aos investidores pela Corretora*”;
- (d) não houve a prática de *churning*, pois não recebera comissão pelas operações realizadas no período compreendido entre março e abril de 2016 e que as aplicações, tanto pessoais quanto dos Reclamantes, resultaram em prejuízos;
- (e) sua atuação era expressamente autorizada pelos Investidores, que assumiram os riscos das operações/aplicações que realizaram, citando como precedente o PAS CVM nº RJ-2010-0051, Dir^a. Rel^a. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 28.08.2012;
- (f) eventual penalidade a ser cominada pelo Colegiado da CVM configuraria violação ao princípio *ne bis in idem*, por já ter sido condenado à reparação, no valor de R\$ 2.300.000,00, em decisão já transitada em julgado;

52. Sobre tais alegações, a SMI pontou, resumidamente, que:

- (a) quanto às imputações de administração irregular de carteiras de valores mobiliários e de uso de senhas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por AAI, a manifestação do Acusado deve ser entendida como confissão, uma vez que confirmaria o consentimento e a cessão de *login* e senha pelos Reclamantes para realizar as operações;
- (b) em relação à imputação de confecção e envio para o cliente de extrato contendo informações sobre as operações realizadas, o Acusado se limitou a negar a infração administrativa, em desacordo com as provas dos autos;
- (c) no que se refere à imputação de *churning*, o Acusado negou ter recebido comissão sobre a corretagem auferida em relação a apenas uma pequena parte do período, o que não afastaria a irregularidade relacionada ao restante das operações;
- (d) não se exige, para se caracterizar a consumação do delito, que a vantagem de natureza patrimonial seja efetivamente obtida pelo agente do ilícito. O eventual sucesso em obter a

⁶⁴ Doc. 1211574, PA CVM nº SP-2016-331.

⁶⁵ Doc. 1234595, PA CVM nº SP-2016-331.

⁶⁶ O Acusado também citou, em sua defesa, o depoimento de M.A.B.P. em processo judicial em que aduziu que acompanhava as operações e pedira, ao AAI, para que elaborar uma planilha para seu acompanhamento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

vantagem ilícita seria um fator agravante à penalidade aplicada, não elemento do delito⁶⁷.

53. Por fim, a Acusação destacou que, como apurado pela BSM, as operações com valores mobiliários realizadas pelo AAI em nome de M.B.A.P. resultaram em lucro bruto de R\$ 722,00 e as realizadas em nome de S.M.O. resultaram em prejuízo bruto no valor de R\$ 1.812.448,20, totalizando prejuízo bruto de R\$ 1.811.726,20⁶⁸.

54. A SMI destacou, ainda, que os fatos analisados já foram objeto de competente ação penal, conforme se pode verificar na decisão acerca do Conflito de Competência nº 156.111/SP⁶⁹.

III. RESPONSABILIZAÇÃO

55. Nos termos do TA, a SMI concluiu pela responsabilização do Acusado:

- i. por administração irregular das carteiras de valores mobiliários dos Reclamantes (infração ao art. 23 de Lei nº 6.385/1976, ao art. 2º da ICVM nº 306/1999 (fatos até 03.01.2016, data em que a ICVM nº 306/1999 foi revogada, com a entrada em vigor da ICVM nº 558/2015), ao art. 2º da ICVM nº 558/2015 (fatos a partir de 04.01.2016) e ao art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011);
- ii. pelo uso de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico (infração ao art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011);
- iii. pela confecção e envio para o cliente de extrato contendo informações sobre as operações realizadas em 11.03.2016 e 15.03.2016 (infração ao art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011); e
- iv. pela realização de negociações excessivamente com o objetivo de gerar receitas de corretagem e comissões para si ou para *outrem*, prática conhecida *churning* (infração ao item I da ICVM nº 8/1979, definida no item II, “c”, da mesma Instrução).

IV. RAZÕES DE DEFESA

56. Regularmente citado⁷⁰, Francisco Frauendorf apresentou suas razões de defesa tempestivamente⁷¹, em 08.11.2021⁷².

57. Em sua defesa, o Acusado sustentou, em termos semelhantes à sua resposta ao Ofício nº 59/2021/CVM/SMI/GME, em síntese, que:

- (a) se exime da responsabilidade pelos alegados prejuízos afirmando, recorrentemente, que os Reclamantes cederam as senhas de acesso ao *home broker*, em ato discricionário e livre, gozando de garantia constitucional⁷³, sendo que as ordens emitidas por meio do sistema

⁶⁷ Citado, p.ex., PAS CVM nº 19957.003798/2017-27, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 09.06.2020: “apesar de o tipo administrativo de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários não exigir a obtenção de vantagem financeira para sua consumação, deve ser considerado que os Acusados lograram obter a vantagem econômica (...).”

⁶⁸ Doc. 0682300, fl. 14.

⁶⁹ Doc. 0619435.

⁷⁰ Doc. 1367761.

⁷¹ Doc. 1384474.

⁷² Doc. 1384270.

⁷³ O Acusado citou o inciso II do art. 5º da CRFB/88 para defender que os Reclamantes estavam dotados de ampla discricionariedade e liberdade ao lhe delegarem a gestão de carteira, como segue, *in verbis*: Art. 5º Todos são iguais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

home broker presumem-se feitas pelo próprio cliente;

- (b) M.A.B.P. acompanhava diretamente todas as operações e conversava diariamente com o Acusado sobre os resultados obtidos, além de possuir, para fins de monitoramento, notas de corretagem enviadas pela Corretora, extratos de custódias da BM&FBovespa, aviso de negociação de ativos, extratos de conta corrente etc.;
- (c) a responsabilidade e a efetividade da cessão da senha eletrônica seriam decorrentes de consenso dos Reclamantes, nos termos pactuados nas Cláusulas 15.2, 15.4 e 15.5 do contrato de intermediação assinado com a Corretora, que previam a responsabilidade do cliente pela cessão de senha e assinatura eletrônica a terceiros, e que a utilização da senha nos sistemas eletrônicos é considerada como manifestação expressa da vontade do cliente;
- (d) os Reclamantes reiteraram, mesmo após perdas de aproximadamente R\$ 200.000,00, a confiança que tinham nele, concordando que continuasse a fazer aplicações de seus ativos;
- (e) sua atuação como AAI se deu dentro dos termos legais e não transferiu nenhum dos valores que lhe foram confiados para conta pessoal ou similar;
- (f) a ciência dos riscos eventualmente advindos dos investimentos foi pactuada pelos Reclamantes na Ficha Cadastral e no Termo de Adesão ao Contrato por eles assinados;
- (g) a ciência dos riscos por parte de M.A.B.P. seria ratificada pela sua formação profissional de advogado e seu perfil agressivo de investidor, e que a ciência das cláusulas contratuais seria “*prova cabal e incontestável*” de domínio, por parte do investidor, quanto ao mercado de valores mobiliários e sua regulação, citando precedente do TJSP⁷⁴ nesse sentido;
- (h) a resposta da Corretora acerca dos valores restituídos aos Reclamantes omitiu os valores de aplicações e de comissões, as quais nunca teria recebido da Corretora no período entre agosto de 2015 a 16.03.2016;
- (i) M.A.B.P. confessou e admitiu sua responsabilidade, durante depoimento em juízo, ao afirmar que “*acompanhava, eu não sou trouxa (...)*”, que “*entrava na conta no final dos dias*” e que “*as perdas (...) não teriam ocorrido ‘só’ por sua culpa*”.

58. Francisco Frauendorf requereu que sejam então aplicados pelo Colegiado os entendimentos de decisões já exaradas, que considera pertinentes a este caso, quanto às quais alegou ter se formado “coisa julgada material e formal” e “coisa julgada administrativa”. Tais decisões atribuem aos investidores responsabilidade em razão da cessão dos acessos ao *home broker* e ciência dos riscos, seguindo a linha apresentada pela, dentre os quais foram destacados:

- (a) manifestação da BM&F Bovespa, na Reclamação nº 304813: “*a própria cliente confessou que compartilhou esses dados com terceiros (...) já está consagrado pela própria CVM o*

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

⁷⁴ TJSP, AC nº 9055546- 53.2001.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Garcoa, 9ª C. (Extinto 1º TAC), j. em 17.09.2002.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

entendimento de que ordens emanadas do home broker são ordens efetivamente por ele emitidas, decorrendo correspondentes prejuízos de seu próprio erro ou decisão de investimento (...) não reconhecemos qualquer irregularidade nas operações realizadas”;

- (b) pedido de ressarcimento dos prejuízos decorrentes das operações realizadas pelo Acusado julgado improcedente no âmbito do MRP nº 499/2016;
- (c) trecho de voto proferido pelo Conselho de Supervisão da BSM, no âmbito do processo MRP nº 12/2011, em que o relator entendeu pela não procedência da reclamação pela cessão espontânea por parte dos investidores de senhas pessoais e intransferíveis a AAI;
- (d) precedente relatado pela então Diretora da CVM Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, no PA nº RJ 2010-0061, julgado em 28.08.2012, em que se entendeu que o acompanhamento e o recebimento, por parte do investidor, de resultados de operações por parte do AAI, significavam concordância com operações realizadas em seu nome; e
- (e) sentença da 2ª Vara Criminal Federal no Processo nº 0008460-19.2016.4.03.6103, em que se concluiu “*não ter sido verificada eventual vantagem auferida por FRANCISCO em possível alteração do funcionamento do mercado*”.

59. Por fim, considerando, ainda, que os Reclamantes estavam cientes dos riscos, Francisco Frauendorf requereu que a Acusação seja julgada “absolutamente improcedente e inconsistente”.

V. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

60. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou⁷⁵ pela adequação do TA ao disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 13 da ICVM nº 607/2019, então vigente. Destacou, também, a necessidade de comunicação ao Ministério Público Federal de São Paulo, tendo sido então expedido o Ofício nº 301/2021/CVM/SGE⁷⁶, em 11.08.2021.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO

61. Na Reunião do Colegiado de 16.11.2021⁷⁷, fui designada por sorteio Relatora deste PAS.

62. Em 15.09.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM⁷⁸, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2023.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

⁷⁵ Parecer n. 00133/2021/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 1320511).

⁷⁶ Doc. 1322864.

⁷⁷ Doc. 1388541.

⁷⁸ Doc. 1881208.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003473/2021-21

Reg. Col. 2386/21

Acusado: Francisco Frauendorf
Assunto: Atuação irregular como agente autônomo de investimento e outras alegadas irregularidades, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976, ao art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, ao art. 2º da Instrução CVM nº 558/2015, ao art. 13, incisos IV, VII e VIII, da Instrução CVM nº 497/2011, e item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face de Francisco Frauendorf, à época agente autônomo de investimento² (“AAI”), em razão de, alegadamente, o Acusado (i) ter exercido irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976³ c/c art. 2º da Instrução CVM (“ICVM”) nº 306/1999⁴ c/c art. 2º da ICVM nº 558/2015⁵ e, ainda, c/c art. 13, IV⁶, da ICVM nº 497/2011; (ii) ter recebido e utilizado senhas de investidores, em infração ao art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011⁷; (iii) ter confeccionado e enviado, a investidores, extrato de operações, em infração ao art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011⁸; e (iv) ter praticado *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM nº 8/1979⁹.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Neste voto será mantida a nomenclatura “agente autônomo de investimento” utilizada no TA, por ser a utilizada à época dos fatos. Após as alterações promovidas pela Lei nº 14.317/2022 na Lei nº 6.385/1976, tais participantes de mercado passaram a ser denominados “assessores de investimentos”.

³ Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

⁴ Art. 2º. A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

A ICVM nº 306/1999 foi revogada e substituída pela ICVM nº 558/2015.

⁵ Art. 2º. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.

A ICVM nº 558/2015 foi revogada e substituída pela Resolução CVM (“RCVM”) nº 21/2021.

⁶ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: (...) IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários.

A ICVM nº 497/2011 foi revogada e substituída pela RCVM nº 16/2021.

⁷ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou (...): (...) VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico.

⁸ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou (...): (...) VIII - confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto.

⁹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2. Como relatado, este PAS teve origem na apuração de irregularidades no PA CVM nº SP 2016-331, instaurado pela SMI, a partir de Reclamação apresentada por dois Investidores, e no PA CVM nº 19957.004377/2017-13, relativo a recurso interposto pelos Reclamantes contra decisão da BSM que julgou improcedente pedido de ressarcimento feito no âmbito do MRP nº 499/2016.
3. Em apertada síntese, a SMI aduziu que o Acusado, registrado como AAI perante a CVM durante o período investigado, contratado pela Corretora entre 15.12.2015 e 07.04.2016, atuou, mesmo sem ter registro ou autorização, como administrador de carteira de valores mobiliários, em exercício irregular de tal atividade em relação aos Investidores (M.A.B.P. e S.M.O.).
4. Ademais, a SMI apontou que o Acusado recebeu e utilizou as senhas de uso exclusivo dos Investidores para transmissão de ordens por meio de plataforma de negociação *Home Broker* da Corretora, além de ter confeccionado e enviado aos Investidores extrato de operações, por duas vezes, em 11.03.2016 e 15.03.2016, em infração ao art. 13, VII e VIII, da ICVM nº 497/2011.
5. Ainda de acordo com a Acusação, Francisco Frauendorf negociou excessivamente ativos que compunham a carteira de investimento dos Investidores, com o propósito de auferir vantagem financeira indevida que consistia em percentual das receitas de corretagem referentes a tais negócios, em detrimento dos interesses desses clientes, prática fraudulenta conhecida como *churning*, em infração ao disposto no item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979.
6. Feita esta breve introdução, passo à análise do caso.

II. PRELIMINAR

7. Inicialmente, cabe afastar, de plano, a alegação do Acusado de que a aplicação de eventual penalidade pela CVM no âmbito deste PAS configuraria violação ao princípio *ne bis in idem*, em razão de Francisco Frauendorf já ter sido condenado a ressarcir os Investidores em decisão transitada em julgado, uma vez que eventual responsabilidade administrativa não se confunde com a civil, tenha essa se refletido tanto no ressarcimento no âmbito do MRP, como detalhado no Relatório, quanto na indenização complementar obtida pelos Investidores por via judicial.
8. A propósito da independência das esferas, a CVM já se manifestou, reiteradamente, no sentido de que a responsabilidade decorrente de determinados ilícitos pode se dar, simultaneamente, nas esferas civil, penal e administrativa, a depender de sua natureza¹⁰. Tais

do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros. A ICVM nº 8/1979 foi revogada e substituída pela RCVM nº 62/2022.

¹⁰ P.ex., PAS CVM SP2011/233, j. 25.03.2014, PAS CVM RJ2013/1852, j. 06.10.2015 e PAS CVM RJ2015/5002, j.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

esferas são independentes e têm, à luz das normas aplicáveis, repercussões e competências de apreciação diversas e visam tutelar diferentes bens jurídicos, sendo que, quanto aos ilícitos em tela, a responsabilidade civil e a penal são apreciadas, em regra, pelo Poder Judiciário.

9. Na esfera administrativa, por sua vez, no âmbito da autorregulação, a atuação da BSM se deu em bases mais restritas e, de todo modo, tampouco restringe a competência da CVM para processar e punir o Acusado pelos ilícitos administrativos em tela. Consoante apontado no Relatório, o PAD BSM nº 24/2017 tratou apenas do descumprimento da vedação do art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011, por Francisco Frauendorf, em razão da utilização de senhas e assinaturas eletrônicas de uso exclusivo dos Investidores, no período de 31.07.2015 a 16.03.2016¹¹.

10. Como igualmente detalhado no Relatório, no âmbito de tal processo, em decisão já transitada em julgado, Francisco Frauendorf foi condenado, pela referida infração ao art. 13º, VII, da ICVM nº 497/2011, ao pagamento de multa de R\$200.000,00, em caráter definitivo¹². A sanção aplicada pela BSM não exclui, porém, a apreciação pela CVM neste PAS. De todo modo, será considerada para fins de dosimetria da pena, em linha com o disposto no art. 62, parágrafo único, da Resolução CVM (“RCVM”) nº 45/2021, como refletido na seção final deste voto.

11. Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar suscitada.

III. MÉRITO

12. Para analisar o mérito deste PAS, divido as questões objeto de exame de acordo com a ordem das diferentes imputações de responsabilidade feitas ao Acusado, pela SMI, no TA.

a) Exercício Irregular de Administração de Carteira

13. O exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários está sujeito à prévia autorização da CVM, como estabelecem o art. 23, *caput*, da Lei nº 6.385/1976 e o art. 2º da ICVM nº 306/1999 (vigente à época dos fatos ocorridos até 03.01.2016) e art. 2º da ICVM nº 558/2015 (vigente à época dos fatos ocorridos a partir de 04.01.2016). Além disso, especificamente para os AAIs, vigia regra específica (art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011) que vedava ao AAI a prestação de tal serviço. Como constatado pela consulta aos registros da CVM, Francisco Frauendorf não tinha autorização da CVM para o exercício dessa atividade profissional.

14. A fim de verificar se as condutas praticadas por Francisco Frauendorf configuraram a

15.03.2016.

¹¹ Cópia do PAD BSM foi juntada aos autos do PA CVM nº SP-2016-331 (Doc. 1030592), tendo todos os documentos sido juntados a este PAS (Doc. 1281979).

¹² A decisão da Instância Recursal do Conselho de Supervisão da BSM está disponível em: <https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-processos/parecer/2017-024-pad>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prática da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, cabe analisar este caso à luz dos diversos precedentes julgados pela CVM¹³. Em síntese, como já discorri no âmbito do PAS CVM nº 19957.004928/2020-44¹⁴, de que fui relatora, são necessários quatro elementos para que se configure a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, quais sejam: (i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor.

15. Assim, passo a analisar se esses elementos estão presentes no caso concreto.

(i) **Gestão**

16. No que tange ao primeiro requisito, a gestão compreende a tomada das decisões de investimento propriamente ditas, pressupondo, como reconhecido pelo Colegiado, a *“liberdade para estabelecer uma estratégia de investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua efetivação, comunicando-os ao cliente posteriormente”*¹⁵.

17. No caso concreto, a conclusão quanto à ampla liberdade concedida pelos Investidores ao Acusado para escolher os ativos e as quantidades a serem negociados e o momento das operações deflui do conjunto probatório juntado aos autos, em especial das diversas declarações, orais e por escrito, do próprio Acusado. Destaca-se o seu depoimento no Inquérito Policial¹⁶, as declarações no âmbito do PAD BSM nº 24/2017 e o conjunto de mensagens trocadas entre Francisco Frauendorf e M.A.B.P. De forma exemplificativa, reproduzo os seguintes trechos dos esclarecimentos prestados no referido Inquérito:

*“(...) [realizou] operações de investimento na forma da legislação e regulamentação em vigor, expressamente autorizadas por eles, inclusive, **com a liberação de senha, no âmbito de sua discricionariedade**, com plena assunção, por eles, dos riscos,*

¹³ Nesse sentido, p.ex., PAS CVM nº RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Marcilio, j. em 17.10.2006; PAS CVM nº RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.03.2009; PAS CVM nº RJ2009/10246, Dir. Rel. Alessandro Broedel, j. em 09.11.2010; PAS CVM nº RJ2011/940, j. em 10.07.2012, e PAS CVM nº RJ2012/9490, j. em 10.03.2015, em ambos Dir.^a. Rel.^a. Luciana Dias; PAS CVM nº RJ2014/11558, j. em 11.08.2015, e PAS CVM nº RJ2014/8297, j. em 08.09.2015, em ambos Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº SP2012/0480, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 06.10.2015; PAS CVM nº RJ2014/2797, j. em 27.09.2016, e PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 10.02.2017, e PAS CVM nº SP2014/014, j. em 12.09.2017, nesses três Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018; PAS CVM nº 04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; PAS CVM nº 17/2013, j. em 25.06.2019, PAS CVM nº 19957.006012/2016-42, j. em 19.11.2019, PAS CVM nº 04/2015, j. em 15.09.2020, e PAS CVM nº 19957.004928/2020-44, j. em 28.09.2021, esses quatro de minha relatoria; PAS CVM nº 19957.003610/2020-46, j. em 09.11.2021, PAS CVM nº 19957.003560/2020-05, j. em 09.11.2021, e PAS CVM nº 19957.002344/2021-15, j. em 25.10.2022, nesses três Dir. Rel. Alexandre Rangel; PAS CVM nº 19957.009400/2019-28, de minha relatoria, j. em 31.01.2023; PAS CVM nº 19957.010926/2022-56, Rel. Pres. João Nascimento, j. em 28.02.2023; PAS CVM nº 19957.011015/2022-46, de minha relatoria, j. em 25.04.2023; e PAS CVM nº 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023.

¹⁴ PAS j. em 28.09.2021.

¹⁵ PAS CVM nº SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06.11.2018.

¹⁶ Doc. 1281979, arquivo “[01]-0579366_Processo”, fl. 88.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

especialmente os de suportar perda financeira em decorrência de liquidação das operações, em face da imprevisibilidade e da volatilidade, próprias do conjunto das operações, a partir de contas mantidas por eles junto à [Corretora].”

“(…) que operava as senhas de [M.A.B.P.] e [S.M.O.] livre e espontaneamente fornecida por eles e o [M.A.B.P.] acompanhava, diariamente, mediante log in todas as operações.”

*“(…) **decidia o que comprar**, porém sempre com o acompanhamento do [M.A.B.P.] e os indicadores de mercado e do site [T. R.] (…).”*

“[realizou] operações de investimento na forma da legislação (...) com a liberação de senha (...) com plena assunção [pelos Reclamantes] dos riscos.”

(ii) Caráter profissional

18. A gestão dos recursos dos Investidores pelo Acusado ocorreu de forma profissional, eis que era cumulada com a atividade de AAI, de forma simultânea, durante todo o período das operações. Cabe também reconhecer que era remunerada, pois o AAI recebia parte da receita auferida pela Corretora. Ainda que tais recursos tivessem o objetivo de remunerar a atividade de AAI, fato é que o controle das operações levou, no caso concreto, como apontado no Relatório e analisado mais adiante, a um giro excessivo da carteira, que seria incompatível com a forma tradicional de um AAI operar com clientes.

19. Com o controle das operações, ainda que monitorado periodicamente pelos Reclamantes, as receitas advindas das ordens comandadas pelo AAI eram provenientes não do exercício regular das atribuições contempladas na ICVM nº 497/2011, mas sim das atividades de gestão. Cabe destacar, além de outras provas juntadas aos autos, o apurado no Inquérito Policial acerca da atuação do Acusado (corroborado com o disposto no contrato de distribuição firmado entre o AAI e a Corretora, intermediário ao qual ele estava vinculado¹⁷): *“sua remuneração (...) era um percentual da taxa gerada pela aplicação dos clientes cadastrados junto à [Corretora]”*.

20. Assim, a meu ver, o conjunto fático-probatório trazido aos autos evidenciou claramente que a atuação do Acusado ocorreu no exercício de atividade profissional, com a continuidade da prestação dos serviços por pelo menos 7 (sete) meses, como se observa das comunicações eletrônicas trocadas entre o AAI e os Reclamantes. Nesse sentido, ao ter sua remuneração parametrizada pela quantidade de operações e natureza dos valores mobiliários, os atos de gestão das Carteiras, no período, também estavam sendo remunerados.

(iii) Recursos entregues ao administrador

21. Em relação aos recursos entregues pelos Investidores, restou evidenciado que o Acusado

¹⁷ No PA CVM 19957.004377/2017-13, o Doc. 0757109 contém o conteúdo de mídia digital (CD), incluindo uma pasta de arquivos (“Documentos AAI”) em que se pode acessar os contratos firmados entre o AAI e a Corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tinha controle sobre as contas dos referidos clientes, a partir do acesso aos dados de *login* e às senhas dos Investidores para acesso ao *home broker*, efetivamente utilizadas para comandar operações em nome dos Reclamantes, ainda que com certo acompanhamento por parte deles, a partir de prestações de contas encaminhadas a M.A.B.P. por meio de mensagens eletrônicas.

22. Registro que, em linha com entendimento há muito sedimentado pelo Colegiado em casos similares¹⁸⁻¹⁹⁻²⁰⁻²¹, não é imprescindível a entrega física de numerário na conta do Acusado, sendo o mesmo efeito produzido pelo fornecimento ao Acusado de *login* e senha de uso exclusivo dos Investidores (como abordado mais adiante, por indução do Acusado).

23. Em suma, em linha com os precedentes, entendo que o elemento da entrega de recursos ao gestor irregular está presente no caso concreto.

(iv) Autorização para aquisição e alienação de valores mobiliários por conta do investidor

¹⁸ V. PAS CVM nº RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.03.2009: “Neste ponto quero destacar que a entrega de recursos ou valores mobiliários não pressupõe, por óbvio, a entrega física dos recursos ao administrador, tampouco que tais recursos transitem necessariamente pelo administrador. O termo “entregar”, no caso, é utilizado no sentido de “por(-se) à guarda ou proteção de; confiar(-se)”, uma das acepções do verbo de acordo com o Dicionário Houaiss. Dessa forma, para a caracterização da atividade de administração de carteira, o que se exige é que o suposto administrador tenha, sob sua confiança, recursos ou valores mobiliários do investidor para que, em nome do investidor, possa geri-los. Ademais, para que se caracterize a administração de carteira de valores mobiliários, o gestor deve ter a faculdade de comprar ou vender valores mobiliários em nome e por conta do investidor de forma profissional, (...)”

¹⁹ V. PAS CVM nº RJ2008/12088, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 09.02.2009: “(...) entrega de recursos ou valores mobiliários não pressupõe, por óbvio, a entrega física dos recursos ao administrador, tampouco que tais recursos transitem necessariamente pelo administrador. O termo “entregar”, no caso, é utilizado no sentido de “por à guarda ou proteção de; confiar”, uma das acepções do verbo de acordo com o Dicionário Houaiss. Dessa forma, para a caracterização da atividade de administração de carteira, o que se exige é que o suposto administrador tenha, sob sua confiança, recursos ou valores mobiliários do investidor para que, em nome do investidor, possa geri-los.”

²⁰ V. PAS CVM nº RJ2008/10874, Dir. Rel. Otávio Yazbek, j. em 28.04.2009: “Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, reputo importante retomar, aqui, o tema da entrega de recursos ao administrador como um dos elementos constitutivos da “administração de carteira de valores mobiliários”, conforme já abordado em meu voto no (...) PAS CVM nº RJ 2008/10181. Em linha com o que consignei à época, acredito que, ainda que tal elemento conste da definição de atividade de administração estabelecida pela citada Instrução CVM nº 306/99, referida caracterização destina-se a uma finalidade distinta – a de delimitar o campo de atuação dos administradores autorizados na forma daquele normativo. Quando se trata de gestão irregular, não se está falando da atividade regularmente autorizada, mas sim de relações concretas, em que ocorre efetiva gestão de carteira mas que são sempre marcadas por peculiaridades. Por esta razão, me parece claro que o arranjo existente entre os Acusados e seus clientes – por meio do qual estes depositavam os valores diretamente em favor das corretoras e meramente se obrigavam a transferir seu login e senha do sistema home broker a [M.A.], que emitia as ordens e operava remotamente – constitui efetiva transferência de gestão, mesmo que não tenha ocorrido entrega de dinheiro pelo investidor diretamente ao administrador.”

²¹ V. PAS CVM nº SP2014/014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017: “14. Nesse sentido, o Diretor-Relator Eli Loria, em voto proferido no PAS CVM nº RJ2008/10181, esclarece que: ‘(...) para a caracterização da atividade de administração de carteira, o que se exige é que o suposto administrador tenha, sob sua confiança, recursos ou valores mobiliários do investidor para que, em nome do investidor, possa geri-los.’ 15. Assim, tal aspecto traduz-se, no presente caso, no controle exercido por [D.C.] sobre os recursos dos Reclamantes, valendo-se indevidamente do contrato firmado entre (...) para emitir ordens em nome e à conta daqueles.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

24. No que se refere à autorização dos Investidores, suas declarações, cumuladas com as do próprio Acusado, como indicadas no Relatório, demonstram que esse elemento restou configurado, não apenas pela cessão de dados de *login* e senha de acesso ao sistema de *home broker* pelos Reclamantes, mas também da análise da dinâmica das interações mantidas entre o AAI e os Reclamantes, que, claramente, conferiram poder ao Acusado para realizar as operações em nome dos Reclamantes, ainda que sob seu acompanhamento.

25. Dessa forma, concluo que restaram evidenciados elementos de autoria e materialidade suficientes para configurar a violação pelo Acusado ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 2º da ICVM nº 306/1999 e art. 2º da ICVM nº 558/2015 c/c art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011.

b) Uso pelo Acusado de senhas eletrônicas dos Investidores

26. Francisco Frauendorf também foi acusado de ter utilizado senha eletrônica de uso exclusivo dos investidores M.A.B.P. e S.M.O. para transmissão de ordens por meio de sistema de *home broker*, durante o período objeto deste PAS, em infração ao art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011.

27. A imputação em questão é fundamentada nos elementos fáticos acima detalhados que corroboram que o Acusado detinha o controle sobre as operações cursadas em nome dos Investidores, tendo, como dito, o próprio Acusado afirmado, em depoimento no Inquérito Policial, que realizou “*operações de investimento na forma da legislação (...) expressamente autorizada por eles, inclusive, com a liberação de senha (...) com plena assunção [pelos Investidores] dos riscos*”; que “*operava as senhas de [M.A.B.P. e S.M.O.] livre e espontaneamente fornecida por eles e [M.A.B.P.] acompanhava, diariamente, mediante log in todas as operações*”; e que “[M.A.B.P. e S.M.O.] *poderiam a qualquer momento modificar as senhas, ou ainda não permitirem as operações que lhe eram avisadas por [ele]*”.

28. No mesmo sentido, tem-se as declarações do Acusado no âmbito do PAD BSM nº 24/2017, em que Francisco Frauendorf foi condenado por essa mesma infração²², tendo aduzido que os Investidores o autorizaram “*livre e espontaneamente, expressamente, no exercício de sua própria discricionariedade, a realizar todas as operações, através do home broker*”, bem como as mensagens trocadas entre o AAI e M.A.B.P, corroboradas pelas operações realizadas em mercado, além da manifestação de Francisco Frauendorf em resposta ao Ofício nº 59/2021/CVM/SMI/GME.

29. Diante do conjunto fático-probatório colacionado, não parece subsistir dúvida sobre o que de fato ocorreu no caso concreto, já que, quanto a esse ponto, não há controvérsia, sendo convergentes as declarações do Acusado e dos Investidores quanto ao compartilhamento das

²² Em decisão transitada em julgado, no PAD BSM nº 24/2017, Francisco Frauendorf foi condenado por infração ao art. 13º, VII, da ICVM nº 497/2011, após recurso, ao pagamento de multa no valor de R\$ 200.000,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

senhas. A contestação do Acusado diz respeito às repercussões do fato de que os Investidores as cederam em ato discricionário e livre. A questão merece ser examinada para distinguir situações fáticas diversas, com diferentes repercussões no campo da responsabilidade administrativa.

30. O argumento é duplamente falacioso.

31. Primeiramente, como bem apontado no TA, os Reclamantes asseveraram, na Reclamação, que cederam suas senhas porque o Acusado teria lhes informado que a prática de usar a senha do *home broker* dos clientes era praxe em relação a investidores com maior capital investido. Se fosse procedente o quanto informado, restaria claro que qualquer AAI que assim orientasse os clientes concorreria para induzi-los em erro, a ponto de poder ser considerado um ardil para que o profissional, de posse dessas informações, pudesse ter o controle efetivo das operações, além de, simultaneamente, dissimular sua atuação perante os controles do intermediário, que poderia não detectar que as ordens comandadas em seus sistemas não eram genuinamente dos clientes.

32. A propósito, vale destacar o quanto aduzido na Reclamação perante a CVM:

“Seguindo ainda a recomendação de Francisco [Frauendorf], e, tendo em vista o desconhecimento que possuíam do mercado de financeiro de capitais, os Autores disponibilizaram a Francisco [Frauendorf] a senha que dava acesso a tais contas, **tendo este, inclusive, feito o cadastro de tais senhas**, conforme documento **manuscrito** por Francisco [Frauendorf], para que este pudesse realizar as movimentações financeiras necessárias à manutenção dos rendimentos dos autores

Repisa-se que Francisco [Frauendorf] explicou que a prática de usar a senha do *home broker* dos clientes era uma **praxe comum** para os clientes com maior capital investido. Cabe destacar, neste ponto, que [M. A.B.P.] foi até a residência de Francisco, local onde também funcionava o seu escritório, e que o próprio Francisco fez o cadastro das senhas dos Autores – deixando registrado em documento **escrito, com a letra de Francisco [Frauendorf]**, as anotações cadastrais pessoais deles.”²³ (grifos aditados)

33. Não obstante tais afirmações constituírem indícios importantes, essas ganham força probatória ainda maior ao se analisar o documento manuscrito, juntado aos autos pelos Reclamantes: um boleto de pagamento, em nome de S.M.O., datado de 15.07.2015, que contém, de fato, anotações a caneta. Verifica-se que essas anotações contêm os números das contas dos dois referidos clientes²⁴, além de menções a senhas. Trata-se de elemento de prova que converge com o afirmado e aponta, de forma consistente, para concluir pela veracidade da narrativa trazida na Reclamação.

²³ Conforme a Reclamação dos Investidores, constante do PA CM nº SP-2016-331, juntado a este PAS no Doc. 1281979. A petição inicial consta do arquivo “[01]-0579366_Processo”, e o trecho acima consta das fls. 5-6.

²⁴ Os autos do PA CVM nº 19957.004377-2017-13, encartado a este PAS no Doc. 1282001, contém dispositivo em mídia que encartado no Doc. 0757109 (Anexo_1_CD_Defesa) em que consta mensagem de 08.11.2016, encaminhada pelo Compliance da Corretora, por meio da qual são encaminhadas duas telas de “Pesquisa de Perfil do Investidor”, uma de S.M.O. e outra de M.A.B.P, nelas constando os mesmos códigos de cliente referidos acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Tendo assim agido influenciados por percepção equivocada da realidade (ao receber orientação de que determinada prática era lícita e comum, quando não o era), não deve ser tido como atuante no pleno exercício de sua liberdade de decisão. Admitir o contrário seria, em boa medida, validar o ardil ao permiti-lo como argumento de defesa de quem induziu terceiro a erro, em violação ao princípio da vedação ao benefício da própria torpeza.

35. Em segundo lugar, tampouco se deve acolher argumento que implique admitir que o AAI desconhecesse as vedações a ele aplicáveis, ainda mais quando o próprio contrato de distribuição e mediação de valores mobiliários por ele firmado com a Corretora estabelece para o AAI a obrigação contratual de “*informar os Clientes do Agente das vedações impostas aos agentes autônomos de investimento pela Instrução CVM n. 497*” (cláusula 3.4.2., alínea “d”)²⁵. O AAI, evidentemente, não operava em erro quanto à existência da vedação de natureza regulatória.

36. Concluo, portanto, que os elementos de informação obtidos pela Acusação não apenas se prestam a comprovar a infração em tela, mas oferecem um conjunto de circunstâncias que qualificam a maior gravidade da conduta, no caso em concreto, tendo em vista a conduta do AAI voltada a induzir os clientes em erro quanto à praxe de mercado. Nesse sentido, as provas permitem desenhar um quadro de iniciativa do profissional, que inclusive participou do cadastro das senhas cujo acesso lhe é vedado, o que permite presumir, logicamente, que houve um agir proativo e consciente que criou uma percepção equivocada da realidade pelos Investidores e nesse erro os manteve durante o período em que realizadas as operações.

37. Improcede, portanto, a alegação de que as senhas teriam sido fornecidas “*em livre e regular exercício da discricionariedade e liberalidade deles investidores*”, cabendo reconhecer como irrefutável, a partir da análise dos autos, a comprovação de que o Acusado se utilizou de senha de uso exclusivo dos Investidores, em infração ao disposto no art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011.

38. Destaque-se, ainda, que a regra descumprida foi erigida justamente para coibir práticas que se encontravam disseminadas no mercado quando da edição da ICVM nº 497/2011, num contexto de grande crescimento do mercado, do número de AAI e pressões concorrenciais. Naquele momento, a CVM, inclusive a partir do recebimento de diversas reclamações, constatou ser comum o entendimento entre investidores de que seriam clientes do AAI e que, em alguns casos, a corretora seria mera prestadora de serviços acessórios ao agente autônomo de investimentos, que supostamente seria o principal responsável pelos investidores.

39. Exatamente com vistas a combater tais condutas, com amplos efeitos deletérios, que a vedação em tela foi instituída, não se tratando, assim, de regra meramente formal, mas sim de

²⁵ No PA CVM nº 19957.004377/2017-13 (Doc. 0757109).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conteúdo substancial, que concretiza escolha da CVM, dentro de uma estratégia regulatória para coibir práticas irregulares e disseminadas no mercado. Com efeito, a gestão irregular de carteira pelo AAI poderia ocorrer pelo próprio acesso das senhas dos clientes, como descrito no Edital de Audiência Pública nº 03/10, em textual:

“dentre tais práticas, encontram-se (i) tanto a gestão propriamente dita (por meio da emissão de ordens pelos agentes autônomos de investimento **ou do uso, por eles, das senhas de home broker/WtR dos próprios clientes**), como (ii) a colocação dos agentes autônomos, nas fichas cadastrais dos clientes por eles apresentados, como representantes destes para uma série de fins”²⁶. (grifos adotados)

c) Confecção e envio de extratos pelo AAI

40. A SMI, a partir da análise de mensagens trocadas entre Francisco Frauendorf e M.A.B.P.²⁷, também propôs a responsabilização do Acusado pela confecção e envio, em duas oportunidades (11.03.2016 e 15.03.2016), de extratos contendo informações sobre as operações realizadas em nome dos Investidores, prática vedada aos AAIs pelo art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011.

41. Insta salientar que a vedação de “*confecionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto*” tem por objetivo assegurar que essa atividade fique estritamente a cargo dos intermediários, que são os responsáveis perante os investidores, inclusive em razão dos atos praticados pelos agentes autônomos²⁸, estando em linha com a política regulatória que a Autarquia pretendeu reforçar com a ICVM nº 497/2011.

42. Quanto a esse ponto, em sua resposta ao Ofício nº 59/2021/CVM/SMI/GME, Francisco Frauendorf se limitou a alegar que os extratos eram enviados pela Corretora aos Investidores. O Acusado também alegou, em sua defesa, que M.A.B.P. acompanhava diretamente todas as operações e conversava diariamente com o Acusado sobre os resultados obtidos, além de contar, para fins de monitoramento, com as notas de corretagem enviadas pela Corretora, extratos de custódias da BM&FBovespa, aviso de negociação de ativos, extratos de conta corrente, etc.

43. Observo, contudo, que há nos autos provas suficientes para concluir que Francisco Frauendorf confeccionou e enviou extratos aos Investidores, como se pode depreender das mensagens enviadas pelo Acusado ao investidor M.A.B.P.²⁹, ao menos nas ocasiões citadas pela Acusação (11.03.2016 e 15.03.2016), contendo planilhas com informações sobre operações que ele realizou em nome dos Investidores nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 de março de 2016, as quais

²⁶ https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2010/sdm0310-edital.pdf.

²⁷ Imagens e áudio de Francisco Frauendorf discorrendo acerca das imagens em Doc. 0757114, pasta anexo IV.

²⁸ Art. 15. A instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários responde, perante os clientes e perante quaisquer terceiros, pelos atos praticados por agente autônomo de investimento por ela contratado.

²⁹ Doc. 0757114, pasta anexo IV, arquivos “IMG_0531”, “IMG_0531”, “2016-03-11-PHOTO-00000309”, “IMG_0536”, “IMG_0538”, “IMG_0539” e “2016-03-15-PHOTO-00000355”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

indicavam os valores referentes ao “lucro líquido” de cada dia obtido nas operações e os valores estimados de imposto de renda incidente sobre o resultado das operações.

44. Ademais, o Acusado afirmou, em áudio, que as planilhas por ele enviadas constituíam “*um controlezinho que eu resolvi fazer hoje até para monitorar meu dia-a-dia. Isso aí são os lucros líquidos de cada dia*”³⁰ e que “*no Excel que eu estou controlando aqui, eu coloquei o lucro de aproximadamente cinquenta mil. Eu coloquei de cinza porque é um valor a confirmar, eu sempre vou me basear no valor da nota de corretagem, certinho, e em azul eu coloquei aproximadamente o imposto de renda em cima desses lucros aí, que é dezenove por cento do total da semana, porque um por cento já é retido na fonte e os outros dezenove por cento tem que pagar em DARF. Então fiz cálculos ali aproximados do lucro líquido do mês que está em cento e oito mil.*”³¹

45. Além disso, corroboram o fato de que o Acusado elaborou o conjunto de informações disponibilizadas as declarações que prestou no Inquérito Policial, ao alegar que “*a pedido de [M.A.B.P.], que monitorava e acompanhava, diariamente, as operações com mais detalhes, pedia ao [AAI] que mandasse os resultados, o que optou por fazer através de planilhas.*”³²

46. Cabe ressaltar que, para a caracterização da infração, não é necessário que se comprove que as informações foram propositalmente manipuladas pelo agente autônomo, mas tão somente que foram por ele elaboradas³³, o que restou comprovado no presente caso.

47. Pelo exposto, entendo que o Acusado deve ser responsabilizado pela referida infração.

d) Prática de operação fraudulenta - Churning

48. Por fim, Francisco Frauendorf foi acusado pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários em razão da alegada negociação excessiva – ou *churning* – quanto à carteira de valores mobiliários de titularidade de S.M.O., no período de 31.07.2015 a 16.03.2016.

49. Como ressaltado pela Acusação, a prática de *churning* é usualmente conceituada como a modalidade de fraude “*realizada por pessoas que, atuando com controle sobre recursos de terceiros, realizam excessivos negócios em nome do cliente, visando não ao melhor interesse do cliente, mas a gerar taxas e comissões para si ou para outrem*”.

50. Consoante precedentes do Colegiado da CVM³⁴, a configuração do ilícito exige a

³⁰ Doc. 0757114, pasta anexo IV, arquivo de áudio “2016-03-11-AUDIO-00000310”.

³¹ Doc. 0757114, pasta anexo IV, arquivo de áudio “2016-03-15-AUDIO-00000356”.

³² Doc. 1281979, arquivo “[01]-0579366_Processo”, fls. 89 e 90.

³³ PAS CVM nº 19957.004737/2017-87, j. em 22.10.2019, Rel. Pres. Presidente Marcelo Barbosa.

³⁴ P.ex., PAS CVM nº 21/2013, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 29.03.2022; PAS CVM nº RJ2020/01228, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 21.12.2021; PAS CVM nº 04/2016, j. em 15.12.2020, PAS CVM nº RJ2016/7486, j. em 18.06.2019, e PAS CVM nº SP2014/0465, j. em 06.11.2018, nesses três Dir. Rel. Gustavo Gonzalez; PAS CVM nº SP2014/382, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 09.10.2018; PAS CVM nº 22/2013, j. em 18.09.2018, PAS CVM nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

comprovação cumulativa dos seguintes elementos objetivos: (i) o controle sobre as operações cursadas em nome do investidor; (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente; e (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões³⁵. Destaque-se, ainda, no aspecto subjetivo, tratar-se de conduta dolosa, como se afigura quanto a todas as infrações previstas na ICVM nº 8/1979.

(i) Controle sobre as operações cursadas em nome do investidor

51. No que se refere ao controle dos recursos, entendo, em linha com a Acusação, que caracterizou-se pelo fato de o Acusado ter atuado com ampla liberdade, dada pelos Investidores, para escolher o momento de iniciar e encerrar posições de investimentos, os ativos e as quantidades a serem negociadas, bem como a direção (compra ou venda) a ser assumida, como referido anteriormente neste voto. Além disso, os depoimentos dos Investidores deixaram claro que o Acusado era o responsável e detinha o controle sobre a realização de negócios em seu nome.

52. Em resposta ao Ofício nº 59/2021/CVM/SMI/GME, o Acusado alegou que não houve *churning*, uma vez que não teria recebido comissão pelas operações feitas no período de março a abril de 2016 e que as aplicações, tanto pessoais quanto dos Investidores, resultaram em prejuízos.

53. O Acusado limitou-se a negar ter recebido comissão sobre a corretagem auferida em relação a apenas uma pequena parte do período das operações, o que, mesmo que fosse confirmado, não afastaria a irregularidade nos dois meses citados, e, claramente, não teria qualquer efeito fora de tal prazo. Ademais, não se exige, para caracterizar a consumação da prática de *churning*, a efetiva obtenção de vantagem de natureza patrimonial pelo autor do ilícito.

(ii) Giro excessivo da carteira de investimentos à luz do perfil do cliente

54. Em relação ao segundo requisito, a Acusação se valeu dos indicadores de adoção consolidada pelos precedentes do Colegiado da CVM e em análises anteriores tanto do autorregulador – BSM – quanto da SMI, dos chamados “*Turn-Over Ratio*” (“TR”), relativo à taxa de giro da carteira, e “*Cost-Equity Ratio*” (“C/E”), referente à razão custo sobre patrimônio.

55. Como já me manifestei em outras oportunidades, em que pese não sejam os únicos elementos a serem aferidos para a caracterização desse tipo de infração, as apurações conduzidas tanto no exterior quanto no Brasil revelam a importância fundamental dos indicadores TR e C/E.

RJ2015/6143, j. em 24.04.2018, e PAS CVM nº 11/2013, j. em 30.01.2018, nesses três Dir. Rel. Gustavo Gonzalez; PAS CVM nº RJ2014/12921, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 10.02.2017; PAS CVM nº SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 06.10.2015; e PAS CVM nº 24/2010, Dir.^a Rel.^a Ana Novaes, j. em 27.05.2014.

³⁵ Tais elementos se coadunam com os requisitos de operação fraudulenta previstos na ICVM nº 8/1979, quais sejam, (i) a utilização de ardil ou artifício (realização de elevado número de negócios que não seguem lógica econômica tampouco se mostravam compatíveis com o perfil dos investidores), (ii) destinado a induzir ou manter terceiros em erro (realização de negócios sem autorização dos clientes) e (iii) com a finalidade de obter vantagem econômica ilícita.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

56. Neste caso, à luz da exorbitância dos indicadores apurados, sequer cabem considerações, a meu ver, quanto a eventuais discrepâncias que poderiam conduzir a dúvidas sobre os resultados a depender da metodologia de cálculo. Ainda que tais indicadores não sejam suficientes para, por si só e independentemente de quaisquer outros aspectos, impor uma condenação, em razão de sua magnitude, não se pode deixar de considerar o peso muito significativo que representam, neste PAS, como fortes indícios de *churning*, como uma presunção relativa quanto à sua ocorrência³⁶.

57. Partindo diretamente para a análise dos indicadores apurados pela BSM, verifica-se haver forte indicação de *churning* quanto à carteira de S.M.O., como bem apontou a Acusação:

Tabela 1 – Indicadores de *Churning* da carteira de M.A.B.P.

Carteira Média (R\$) A	Volume de Compras (R\$) B	Custos Totais (R\$) C	Resultado Líquido (R\$) D	Turnover Ratio B/A	Cost-Equity Ratio (%) C/A	Rentabilidade (%) D/A
1.378.393,40	8.185,00	73,15	648,85	0,006	0,01%	0,05%

Tabela 2 – Indicadores de *Churning* da carteira de S.M.O.

Carteira Média (R\$) A	Volume de Compras (R\$) B	Custos Totais (R\$) C	Resultado Líquido (R\$) D	Turnover Ratio B/A	Cost-Equity Ratio (%) C/A	Rentabilidade (%) D/A
708.242,27	59.502.314,69	297.347,34 ^a	(2.109.795,54)	84	42%	(298%)

58. Como mencionado anteriormente, os cálculos realizados pela BSM, para análise do caso concreto, foram ajustados pela SMI, para considerarem o período das operações, de aproximadamente 7,5 meses, e as despesas reais incorridas (a partir das notas de corretagem). Com essas alterações, há significativa piora nos indicadores, a partir da perspectiva da investidora:

Carteira Média (R\$) A	Volume de Compras (R\$) B	Custos totais (R\$) C	Corretagem e taxas operacionais auferidas pela Corretora D	Turnover Ratio ((B/A) x (12 / 7,5))	Cost-to-equity ratio ((D/A) x (12 / 7,5))	Cost-to-equity ratio ((C/A) x (12 / 7,5))
708.242,27	59.502.314,69	274.918,85	198.878,72	134,42	44,93%	62,11%

³⁶ Apenas a título ilustrativo, transcrevo o seguinte trecho do Ofício-Circular nº 5/2019-CVM/SMI, que remete à jurisprudência do Colegiado da CVM: “7. Os precedentes ressaltam que não se pode, à luz da legislação vigente, definir métricas puramente objetivas para a mensuração do giro excessivo. Destaca-se, nesse sentido, que o perfil do investidor é a melhor medida para aferir se o giro foi, de fato, excessivo. Nesse sentido, veja-se por exemplo o Processo Administrativo Sancionador 11/2013, julgado pelo Colegiado da CVM em 30/01/2018. 8. Não obstante, a literatura especializada e a jurisprudência, daqui e do exterior, se valem de indicadores do *churning*, dentre os quais destacam-se, por sua ampla utilização: a) Taxa de giro da carteira (Turnover Ratio: ‘TR’) b) Razão do custo sobre patrimônio (Cost/Equity Ratio: ‘C/E’) 9. Os indicadores objetivos, tais como o ‘TR’ e o ‘C/E’, fornecem apenas indícios de *churning* e nem sempre bastarão para demonstrar a prática do ilícito. Em outras palavras, o fato de a carteira ter sido movimentada em volume superior à média de mercado, ou os custos incorridos nas negociações terem consumido uma parcela expressiva do patrimônio investido, não demonstram, por si só, uma irregularidade, e, sim, uma presunção relativa de irregularidade.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

59. Pelos números apontados acima, portanto, os patamares em geral considerados para a caracterização de *churning* (TR acima de 8 e C/E acima de 21%) foram em muito superados nas operações realizadas pelo Acusado: (i) o TR para a carteira de S.M.O. ficou em 134,42; e (ii) os C/E, por sua vez, ficaram entre 44,93% e 62,11% (para custos totais, como fez a BSM). Em síntese, constatou-se que houve giro excessivo na carteira de S.M.O., com elevadas despesas incorridas com corretagem e taxas operacionais, parte das quais, por disposição contratual, deveriam ser revertidas para o AAI, como relatado.

(iii) Intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões

60. Com relação ao terceiro requisito do ilícito, vale destacar que a jurisprudência do Colegiado analisa a prática de *churning* à luz dos contornos para a caracterização de operação fraudulenta, nos moldes da ICVM nº 8/1979, como “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.”

61. Consoante bem apontado pelo então Diretor Gustavo Gonzalez³⁷, os precedentes refletem que o “ardil” resta configurado pela realização de operações excessivas³⁸. O controle dos recursos do investidor – que acredita na existência de uma estratégia de investimento no seu melhor interesse – pelo agente consiste na *manutenção de terceiro em erro*. Por fim, a taxa de corretagem é a *vantagem patrimonial* que se busca obter por meio da fraude³⁹.

62. Neste caso, a conduta do Acusado perante os Investidores foi claramente dolosa, como se depreende da seção anterior deste voto, e a intenção de gerar corretagem também ficou evidenciada pelo contrato entre a Corretora e o AAI, que previa remuneração desse pela aplicação de percentual gerado pelas operações intermediadas⁴⁰. Como apontado, a base de cálculo das receitas do Acusado eram as receitas auferidas pela Corretora, a partir dos negócios realizados em nome dos Investidores, sobre as quais ele percebia, segundo a área técnica, entre 50 e 55%⁴¹, consoante previsto nos contratos e aditamentos pactuados entre Francisco Frauendorf e a Corretora⁴².

³⁷ PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, decisão deliberada na reunião do Colegiado de 13.03.2018.

³⁸ V. PAS CVM nº SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes: “entendo que assiste razão à acusação ao apontar o giro intenso da carteira do Reclamante como sendo o ardil ou artifício utilizado para mantê-lo em erro”. PAS CVM nº 24/2010, j. em 27.5.2015, Dir.^a Rel.^a Ana Dolores Novaes: “O meio malicioso, no caso concreto, era, justamente, o giro excessivo da carteira”. PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 10.02.2017, Dir. Rel. Pablo Renteria: “o ardil, consistente no giro excessivo da carteira, em evidente abuso da confiança dos clientes”.

³⁹ PAS CVM nº SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, item 36; PAS CVM nº 24/2010, j. em 27.5.2015, Dir.^a Rel.^a Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, item 95. PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 10.02.2017, Dir. Rel. Pablo Renteria, item 43, “c”.

⁴⁰ Doc.0757109, pasta “Documentos AAI”.

⁴¹ O percentual variava conforme o valor mobiliário, havendo previsão de rebates ainda maiores para certos ativos.

⁴² Doc. 0757109, pasta “Documentos AAI”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

63. Nesse sentido, o próprio Acusado informou, ainda, que recebia parcelas sobre a corretagem gerada em cima de negócios realizados em nome dos Investidores⁴³. Assim, considerando os números elevados dos indicadores TR e C/E, bem acima dos parâmetros indicativos de *churning*, para a carteira de S.M.O., a corretagem gerada em virtude dos negócios e as alegações dos Investidores, entendo que restou caracterizada a prática de *churning* e, por conseguinte, a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, segundo disposto na alínea “c” do item II da ICVM nº 8/1979, infringindo, portanto, a vedação prevista no item I da mesma Instrução.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

64. Pelo exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pelas infrações a: (i) art. 23 da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 2º da ICVM nº 306/1999 (quanto aos fatos ocorridos até 03.01.2016) e art. 2º da ICVM nº 558/2015 (quanto aos fatos ocorridos a partir de 04.01.2016) c/c art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011; (ii) art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011; (iii) art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011; e (iv) Item I c/c II, “c”, da ICVM nº 8/1979.

65. Passo, assim, à dosimetria das penalidades.

66. As infrações administrativas foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual será aplicável a legislação consoante vigente à época dos fatos.

67. Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição, sendo que, em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência.

68. Antes de tratar da dosimetria em si cabe tecer breve consideração sobre as circunstâncias do caso concreto, na perspectiva dos prejudicados pelas condutas objeto deste PAS.

69. O primeiro aspecto diz respeito aos recursos disponíveis para investimento. Consoante descrito na Reclamação, o montante disponibilizado pelos Reclamantes, cônjuges, representava patrimônio amealhado com recursos próprios e, ainda, herança deixada pelos avós maternos de S.M.O., sendo que as circunstâncias fáticas e condições pessoais descritas deveriam ter orientado os objetivos de investimento e perfil de risco, mediante processo adequado de *suitability*.

70. Ocorre que, com as senhas de acesso ao *home broker*, o Acusado passou a ter controle de todo o patrimônio financeiro disponível para investimento, que foi transferido para a Corretora por orientação do AAI e que, após alguns meses de operações, foi dilapidado em poucos dias no início de 2016, em estratégias com opções de compra e venda de ações. O giro excessivo da carteira

⁴³ Doc. 1281979, arquivo “[01]-0579366_Processo”, fl. 89.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

gerou altas despesas com corretagem e ampliou o insucesso da estratégia escolhida (e o prejuízo para o cliente⁴⁴), em estratégia desenhada por quem, insta repisar, não apenas não era autorizado a administrar carteiras de terceiros: esta atividade lhe era expressamente vedada.

71. A preservação das regras que disciplinam tais vedações refletem escolhas regulatórias para proteger os investidores, tendo relevância ímpar. Os casos graves, inclusive sob a perspectiva dos prejudicados, devem receber reprimendas à altura da gravidade, reforçando, no exercício da pretensão punitiva, as escolhas regulatórias que visam coibir condutas capazes de colocar em cheque a confiança dos investidores nas instituições e nos profissionais do mercado de capitais.

72. Feitas essas considerações sobre as circunstâncias do caso concreto, do ponto de vista dos que sofreram com as condutas ora sob exame, passo à dosimetria em si.

73. Como se extrai do art. 23⁴⁵ da ICVM nº 497/2011 então vigente (e assim permanece na RCVM nº 16/2021), as infrações citadas são consideradas graves para efeito de imposição das penalidades previstas na Lei nº 6.385/1976. Assim como a infração por administração irregular de Carteira, a teor do art. 18 da ICVM nº 306/1999⁴⁶ e do art. 32 da ICVM nº 558/2015⁴⁷.

74. Vale repisar que o Acusado já foi condenado no âmbito do PAD BSM nº 24/2017 à pena de multa pecuniária de R\$ 200.000,00, pela infração ao art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011, o que faço refletir em redução de 2/3 do montante da multa que seria, de outro modo, aplicada. Ressalto que a utilização das senhas dos clientes teve amplo espectro, inclusive para a movimentação dos recursos financeiros disponíveis dos Investidores, não se tratando, neste caso, de mera conduta meio para consecução da prática de *churning*, razão pela qual deve ser apenada em separado.

75. No que concerne à administração irregular de carteiras de valores mobiliários, entendo que a imposição de multa pecuniária não seria suficiente para atender adequadamente às finalidades da sanção administrativa, considerando as particularidades do caso concreto, sendo cabível aplicar, diante das diversas infrações apuradas e em linha com precedentes, além de multas pecuniárias

⁴⁴ A Acusação destacou que, como apurado pela BSM, as operações com valores mobiliários realizadas pelo AAI em nome de M.B.A.P. resultaram em lucro bruto de R\$ 722,00 e as realizadas em nome de S.M.O. resultaram em prejuízo bruto no valor de R\$ 1.812.448,20, totalizando prejuízo bruto de R\$ 1.811.726,20.

⁴⁵ Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I - o exercício da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3º, 10 e 11 desta Instrução; (...) III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução.

⁴⁶ Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II, V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.

⁴⁷ Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3º, da Lei nº 6.385, de 1976, o exercício das atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30 e 31 desta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para as demais infrações⁴⁸⁻⁴⁹, pena de proibição temporária para o exercício de atividade que dependa de autorização ou registro perante a CVM⁵⁰, bem como para atuar, direta ou indiretamente, qualquer modalidade de operação no âmbito do mercado de valores mobiliários⁵¹.

76. De outro lado, considero os bons antecedentes do Acusado perante a CVM.

77. Assim, pelo exposto, voto, com fundamento no art. 11, incisos II, VII e VIII, da Lei nº 6.385/1976, e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela **condenação** de **Francisco Frauendorf**, às penalidades de:

(i) **proibição temporária**, pelo prazo de **30 meses**, para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários e exercer qualquer atividade que dependa de autorização ou registro perante a CVM, pelo exercício irregular de administrado carteiras de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 2º da ICVM nº 306/1999 (quanto aos fatos ocorridos até 03.01.2016) e art. 2º da ICVM nº 558/2015 (quanto aos fatos ocorridos a partir de 04.01.2016) c/c art. 13, IV, da ICVM nº 497/2011;

(ii) **multa pecuniária** no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), por ter praticado operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, consoante definida na alínea “c” do item II da ICVM nº 8/1979 e vedada pelo item I;

(iii) **multa pecuniária** no valor de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), por ter recebido e utilizado a senha dos Investidores, em infração ao disposto no art. 13, VII, da ICVM nº 497/2011; e

(iv) **multa pecuniária** no valor de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), por ter confeccionado e enviado extratos aos Investidores, em infração ao disposto no art. 13, VIII, da ICVM nº 497/2011.

78. Por fim, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no

⁴⁸ P.ex., PAS CVM RJ 2018/269, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 22.10.2019.

⁴⁹ P.ex., PAS CVM nº 21/2013, Pres. Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 29.03.2022; PAS CVM nº 04/2016, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 15.12.2020; PAS CVM nº 17/2013, de minha relatoria, j. em 25.06.2019; PAS CVM nº SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº SP2014/0382, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 09.10.2018; PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018; e PAS CVM nº SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 06.10.2015.

⁵⁰ P.ex., PAS CVM nº RJ2020/01227, de minha relatoria, j. em 20.09.2021; PAS CVM nº RJ2019/467, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 05.11.2019; PAS CVM nº RJ2018/269, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 22.10.2019; e PAS CVM nº 17/2013, de minha relatoria, j. em 25.06.2019.

⁵¹ P.ex., PAS CVM nº 04/2016, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 15.12.2020; PAS CVM nº RJ2017/4214, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 22.10.2019; PAS CVM nº 04/2014, Dir. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; PAS CVM nº RJ2016/5179, j. em 30.10.2018, e PAS CVM nº 07/2013, j. em 08.10.2019, em ambos Dir. Rel. Henrique Machado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 301/2021/CVM/SGE⁵², de 11.08.2021, e à Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos - DPF/SJK/SP, em complemento à resposta ao Ofício nº 4023469/2023 - DPF/SJK/SP⁵³, de 02.10.2023, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2023.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

⁵² Doc. 1322864.

⁵³ Doc. 1892599.